Marion Larouer, MCF Droit privé, École de droit de Toulouse, UT Capitole

Culture Judiciaire

Droit de la Common Law

Institut d'Études Judiciaires,
UT Capitole,
Année universitaire 2025–2026

INTRODUCTION

1. Présentation rapide et dichotomie avec le droit continental

La common law est intimement liée au droit anglais. Son histoire est exclusivement celle du droit anglais jusqu'au XVIIIe siècle.

Les pays ayant adopté la common law sont d'anciennes colonies britanniques, toutes dotées désormais de leur propre droit dérivé :

- États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Irlande, Inde, Afrique du Sud, Israël.

> 💡 **Remarque**
> *Il n'existe pas UNE mais PLUSIEURS common laws, même si de nombreux principes, raisonnements et procédures leur sont communs. Elles forment une grande famille de droit.*

Champ d'application du droit anglais

Le droit anglais régit l'**Angleterre et le Pays de Galles**. Les **Judicature Acts 1873-1875** donnent à l'organisation judiciaire sa forme moderne.

🏴 L'Écosse — un système mixte unique

En vertu du Traité d'Union de 1707, l'Écosse conserve des particularismes juridiques. Elle présente un système unique combinant :

- Un droit civil non codifié remontant au Corpus Juris Civilis,
- Des éléments de common law antérieurs au Traité d'Union.

> ⚠️ **Point important**
> *La common law écossaise se distingue par la place plus importante accordée aux principes de justice naturelle et d'équité.*

🌍 Systèmes juridiques mixtes comparables

Des systèmes pluralistes fonctionnent également au Québec, en Louisiane et en Afrique du Sud.

🇮🇪 Irlande du Nord vs République d'Irlande

- **Irlande du Nord** : Son droit provient du Parlement du Royaume-Uni, de l'Assemblée d'Irlande du Nord (lorsqu'elle est active) et de la jurisprudence. Le droit anglais influence fortement son évolution. Ses lois doivent respecter les actes du Parlement britannique et les traités internationaux signés par le Royaume-Uni.

- **République d'Irlande** : Le droit est fondé sur la Constitution, les lois adoptées par l'Oireachtas (le Parlement irlandais), la jurisprudence, ainsi que les traités et directives de l'Union européenne.

- **Post-Brexit** : l'Irlande du Nord applique encore certaines règles de l'UE (commerce et douanes).

La distinction common law/civil law

Le **droit romain** s'est propagé sur le continent européen et a engendré la **tradition civiliste**, par la suite exportée en Amérique latine, en Afrique et même en Asie (Turquie ou Japon).

La famille romano-germanique comprend de façon classique les systèmes de droit **faisant dépendre les solutions juridiques de la loi**.

- La codification justinienne (Corpus Juris Civilis 529-533) en est l'un des symboles, et
- le Code civil napoléonien de 1804 marque le début de la codification moderne en Europe.

On **oppose** traditionnellement le droit romain et la common law.

Dans les systèmes romano-germanistes, la loi est la source principale de droit, alors que la common law est produite par les juges.

Le légicentrisme civiliste est issu de la conception révolutionnaire de la loi, expression de la volonté générale, qui ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire.

La tradition civiliste considère également que l'administration ne peut être régie par les mêmes règles que les personnes privées.

- La **dichotomie droit public/droit privé** est donc fondamentale sur le continent européen,
- alors que la **common law** est marquée par une égalité de droits.
- Les **droits subjectifs** sont au cœur de la tradition civiliste,
- au contraire de la common law qui est avant tout centré sur **les voies de recours offertes à l'individu**.

Document 1 : Synthèse de la distinction common law/civil law

Critères	Droit civil (Europe continentale)	Common law (pays anglo-saxons)
Distinction droit public/droit privé	Fondamentale : séparation nette entre les deux branches	Moins marquée : primauté d'une égalité des droits
Approche des droits	Basée sur les droits subjectifs reconnus aux individus	Centrée sur les voies de recours et les précédents judiciaires
Source principale du droit	Lois et codes écrits	Jurisprudence et décisions des tribunaux
Rôle des juges	Appliquer la loi votée par le législateur	Interpréter la loi et créer des précédents
Stabilité du droit	Forte, avec des règles codifiées	Évolutive, basée sur les décisions de justice passées

2. La Polysémie de l'expression « Common Law »

Le terme common law a plusieurs **acceptions en anglais.**

À l'origine, ce mot signifie le droit tel qu'il est administré par les **cours royales** siégeant à Westminster et plus particulièrement en français jusqu'en 1650.
Cette commune ley se nomme ainsi pour **différencier ce droit des différents systèmes juridiques existant dans le royaume**, surtout **au nord** où les barons ont toujours droit de haute et basse justice et appliquent un droit directement issu des coutumes féodales et du droit anglo-saxon.

> 💡 **Remarque**
>
> ***1. La Basse Justice (Infangthief) :***
> *Elle concernait les délits mineurs et les affaires locales impliquant les serfs et les habitants du fief. Un baron pouvait juger des infractions comme le vol, les querelles ou les litiges fonciers de faible importance. Ces affaires étaient généralement traitées dans la manorial court (cour seigneuriale).*
>
> ***2. La Haute Justice (Outfangthief) :***
> *Elle donnait au baron le pouvoir de juger des crimes graves, comme l'homicide ou le vol commis par des étrangers sur ses terres. Dans certains cas, un baron disposant de la haute justice pouvait également infliger des peines sévères, y compris la peine de mort.*
> *Le degré de juridiction dépendait des libertés (privilèges) accordées par le roi. Seuls certains seigneurs possédaient la haute justice, notamment les grands barons ou ceux ayant des libertés palatines (comme les comtes de Chester ou les ducs de Lancaster).*
> *Avec le renforcement du pouvoir royal, notamment sous les Plantagenêts, ces droits seigneuriaux ont progressivement été limités, au profit de la justice royale centralisée.*

Ce droit issu de la common law des cours royales sera le seul **droit commun** à tout le royaume d'Angleterre du Moyen Âge à la Renaissance, époque où il s'imposera définitivement.

En anglais juridique moderne, l'expression common law signifie **une partie du droit par rapport à l'equity** (jurisprudence du chancelier) et à la **législation**. Cette branche du droit (common law) est directement issue des cours historiques royales de common law.

Mais le terme signifie aussi **jurisprudence** ; par exemple, on dira qu'une infraction est de common law pour dire qu'elle n'a pas été prévue par un texte de loi mais qualifiée ainsi au cours des siècles par les différents arrêts.

Cette désignation signifie enfin le **droit positif,** le droit applicable.

PARTIE 1 — HISTOIRE DE LA COMMON LAW

SECTION 1. HISTOIRE DU DROIT ANGLAIS

§1. Origines

La common law trouve ses origines dans le droit anglais après la conquête normande (1066), lorsque Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, accède au trône.



🏰 Avant 1066 — La justice locale

La common law trouve ses origines dans le droit anglais après la conquête normande (1066), lorsque **Guillaume le Conquérant**, duc de Normandie, accède au trône.

Avant cette date (1066), l'Église a une influence très grande, puisque des **tribunaux ecclésiastiques** cohabitent avec les tribunaux ordinaires, jugeant en vertu du droit canon les affaires civiles (mariage et séparation). La **justice ordinaire est avant tout locale** (tribunaux de comté). La **coutume** a également une place importante, trouvant ses origines dans les pratiques imposées par les différents peuples ayant occupé le pays (anglais, danois, saxons).

Ainsi avant la stabilité institutionnelle imposée à l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066, les Anglais, comme de nombreuses autres sociétés, notamment les cultures germaniques d'Europe continentale, étaient régis par des **coutumes locales non écrites** qui variaient d'une communauté à l'autre et étaient appliquées de manière souvent arbitraire.

> 📌 **Exemple**
>
> Les tribunaux étaient généralement constitués d'assemblées publiques informelles qui évaluaient les revendications contradictoires dans une affaire et, si elles ne parvenaient pas à prendre une décision, pouvaient demander à un accusé de tester sa culpabilité ou son innocence en portant un fer rouge ou en arrachant une pierre d'un chaudron d'eau bouillante ou un autre "test" de véracité. Si la blessure de l'accusé guérissait dans un délai prescrit, il était libéré car jugé innocent ; dans le cas contraire, l'exécution était généralement prononcée.

👑 Henri II (1154) — Institutionnalisation de la Common Law



En 1154, Henri II, premier roi Plantagenêt, institutionnalise la common law en :

- Créant un système unifié de droit commun,
- Élevant les coutumes locales au rang de droit national,
- Mettant fin aux particularités locales et aux recours arbitraires,
- Établissant un système de jury composé de citoyens ayant prêté serment.

Henri II développe la pratique d'envoyer des **juges de sa cour centrale pour entendre les litiges à travers le pays.**

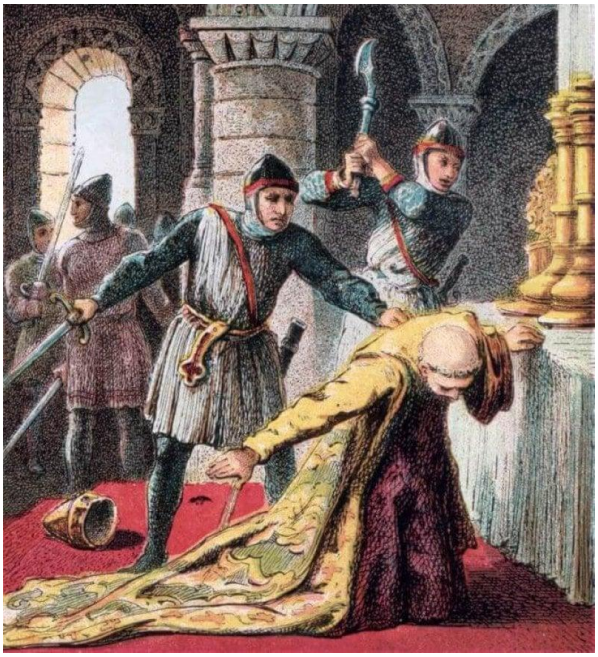
Ses juges tranchaient les litiges sur une base ad hoc en fonction de leur interprétation des coutumes. Les juges du roi retournaient ensuite à Londres et discutaient de leurs affaires et de leurs décisions avec les autres juges. Ces décisions étaient enregistrées et classées.

Avec le temps, une règle, appelée **stare decisis** (également connue sous le nom de précédent), s'est développée.

> 📖 **Définition**
>
> *Le stare decisis (« s'en tenir aux choses décidées ») est la règle par laquelle un juge suit les décisions antérieures lorsque les faits sont similaires. C'est ainsi que naquit la common law unifiée.*

> 💡 **Remarque**
>
> Grâce à ce système de précédents, les décisions s'étoffaient et devenaient plus cohérentes, et c'est ainsi que le système pré-normand de coutumes locales disparates a été remplacé par un système élaboré et cohérent de lois communes à tout le pays, d'où le nom de " common law ".

La création par Henry II d'un système judiciaire puissant et unifié, qui limitait le pouvoir des tribunaux canoniques (de l'Église), l'a amené (ainsi que l'Angleterre) à entrer en conflit avec **l'Église, notamment avec Thomas Becket, l'archevêque de Canterbury.** Le conflit se résout finalement, du moins pour un temps, en faveur d'Henry lorsque quatre de ses chevaliers assassinent Becket dans la cathédrale de Canterbury.



Représentation de l'assassinat de Thomas Becket par Joseph Martin Kronheim. 1868.

> 💡 **Remarque**
>
> La common law élaborée par les juges est devenue l'autorité uniforme dans tout le royaume plusieurs siècles avant que le Parlement n'acquière le pouvoir de faire des lois.
> Contrairement aux lois parlementaires (Acts of Parliament), la common law n'est écrite de manière définitive nulle part. Pour identifier une règle, il faut examiner les décisions judiciaires pertinentes.

🏛 Les tribunaux royaux — La Curia Regis

Après 1066, la curia regis (roi et sa cour) exerce des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. **En matière judiciaire, elle ne tranche que de rares affaires** relatives à la paix du royaume ou lorsque les juridictions locales sont empêchées.

De cette curia regis découlent trois tribunaux royaux :

- King's Bench — affaires liées à la monarchie
- Court of Common Pleas — affaires purement privées
- Court of Exchequer — affaires financières et fiscales

Ces juridictions ne sont pas souveraines car le roi retient la justice et car le Parlement a un pouvoir supérieur. Il s'agit de juridictions d'exception, qui ne peuvent remplacer la justice locale.
La **jurisprudence** (*case law*) est ensuite élaborée par les juges royaux itinérants qui portent la justice royale au sein des territoires. Des circuits sont ainsi définis géographiquement.

> 📖 **Définition**
>
> *La common law désigne à ce moment-là le droit produit par les cours royales d'Angleterre et les juges royaux.*

La jurisprudence devient progressivement commune sur l'ensemble du territoire, **renversant la jurisprudence locale (seigneuriale notamment)**. Les juges royaux qui élaborent la jurisprudence commune à l'ensemble de l'Angleterre ont pour but de concurrencer les juridictions seigneuriales.

Ce droit jurisprudentiel est enseigné par les praticiens du droit et consigné dans les ***year books***.

> 💡 **Remarque**
>
> La common law n'établit pas les règles de la société, ne proclame pas de droits, mais établit les règles procédurales pour garantir la justice (remedies precede rights). Elle est essentiellement pratique, pragmatique et d'origine judiciaire. Elle ne connaît pas la distinction droit public/droit privé.

📋 Le *Writ* — Mécanisme procédural fondateur

Plusieurs types de *writs* existent en fonction de l'action formée et surtout de la procédure qui doit être respectée.

> 📖 **Définition**
> *Le writ est émis par le Chancelier au nom du roi, autorisant un individu à mener une action en justice. C'est un ordre du roi, écrit en latin sur un parchemin portant le sceau royal.*

C'est par cet ordre que le roi intervient pour régler une situation d'infraction ou de trouble. Les *writs* proposent des solutions pour gérer ou trancher un conflit : ils indiquent comment régler le problème et sont destinés à garantir la paix.

Au milieu du XIIe siècle et surtout au XIIIe siècle, les *writs* s'institutionnalisent. La chancellerie se met à garder une trace des *writs* précédents, qui cessent d'être des solutions au cas par cas, pour devenir des formules fixes que les plaideurs peuvent obtenir. Un répertoire des *writs* existants se met en place. Il en existe une quarantaine en 1189. Les *writs* prolifèrent, ce qui entraîne une extension de la juridiction royale, qui se banalise, alors qu'elle était auparavant perçue comme exceptionnelle.

> 📌 **Exemple**
> **Writ of Mandamus** : ordre donné à une autorité publique d'accomplir un devoir légal.
> **Writ d'habeas corpus** : protège l'individu contre la détention illégale.
> À l'origine, **l'habeas corpus** était un ordre du roi obtenu par un prisonnier ou en son nom, qui convoquait le prisonnier au tribunal pour déterminer s'il était détenu en vertu d'une autorité légale. L'habeas corpus s'est développé au cours de la même période que la Magna Carta, ou Grande Charte, de 1215, qui déclarait certaines libertés individuelles, l'une des plus célèbres étant qu'un homme libre ne pouvait être emprisonné ou puni sans le jugement de ses pairs en vertu de la loi du pays - établissant ainsi le droit à un procès devant jury.

📋 Les Forms of Action

Les forms of action étaient les différentes catégories de poursuites judiciaires acceptées par les tribunaux de common law. Chaque forme d'action correspondait à un type spécifique de plainte et nécessitait un writ particulier. Elles structuraient la procédure judiciaire et dictaient quelles preuves étaient admissibles et quels remèdes étaient disponibles.

Les procédures et règles de droit applicables sont différentes en fonction de la form of action.

> 📌 **Exemple**
> Par exemple, si le plaideur choisit le trespass, il ne peut présenter que des preuves admises pour ce type d'action. Ce n'est qu'en 1854 que les plaideurs sont autorisés à se fonder simultanément sur deux forms of actions.

- Trespass — atteinte à la personne ou aux biens
- Debt — recouvrement de dettes
- Assumpsit — contrats
- Ejectment — récupération de biens immobiliers

> ⚠️ **Point important**
> Les forms of action ont été abolies en 1873 avec le **Judicature Act**. Le système moderne permet d'intenter une action en justice sans se limiter à une forme rigide. Les writs existent toujours sous certaines formes (procédure administrative et constitutionnelle).

Document 2 : Différences entre writ et form of action

Critère	Writ	Form of Action
Définition	Document juridique ordonnant une action ou une comparution devant la cour.	Catégorie procédurale définissant le type d'action en justice.
Rôle	Moyen d'introduire une affaire en justice.	Détermine la nature de la plainte et la procédure applicable.
Exemples	*Writ of Habeas Corpus, Writ of Mandamus, Writ of Prohibition.*	*Trespass, Debt, Assumpsit, Ejectment.*
Évolution	Certains writs existent toujours dans des contextes spécifiques.	Aboli en 1873 avec le *Judicature Act.*

👥 Le Jury — Origines médiévales

En 1215, l'Église interdit aux prêtres de participer à certaines procédures judiciaires. Les juges anglais ont donc dû élaborer d'autres moyens de preuve, en faisant participer des personnes de la localité. Progressivement, le jury a fait appel à des témoins et les témoignages sont devenus l'élément fondamental de la prise de décision.

§2. Évolution

⚖️ XIXe siècle — Les Judicature Acts 1873-1875

Les **Judicature Acts 1873-1875** et l'**Appelate Jurisdiction Act 1876** unifient l'organisation judiciaire en fusionnant la common law et l'equity.

Ce texte :

- Fusionne les tribunaux de common law et d'equity en une seule juridiction = Supreme Court of Judicature,
- Permet à toutes les divisions judiciaires d'appliquer à la fois la common law et l'equity,

- Établit la règle que l'equity prévaut en cas de conflit,
- Modernise les procédures et crée une nouvelle Cour d'appel.

Au XX[e] siècle, c'est **l'influence du droit européen** (droit du Conseil de l'Europe et droit de l'Union européenne) qui est la plus marquante.

EU XXe siècle — L'influence européenne

> 📜 **Texte de référence**
>
> En vertu de l'European Communities Act (ECA) 1972, jusqu'à l'entrée en vigueur du Brexit, le droit communautaire puis européen prévalait sur toute norme britannique, même une loi postérieure.

> 📜 **Texte de référence**
>
> Le Human Rights Act 1998 (en vigueur depuis le 1er octobre 2000) introduit le droit de la Convention européenne des droits de l'homme en droit britannique. Les arrêts de la Cour de Strasbourg doivent être une source d'inspiration mais ne lient pas les tribunaux britanniques.

Les sections 3 et 4 du Human Rights Act représentent le mécanisme central d'application de la Convention :

- Section 3 : les juges doivent interpréter la loi dans la mesure du possible de manière compatible avec la CEDH.
- Section 4 : les tribunaux peuvent rendre une déclaration d'incompatibilité — sans invalider la loi.

SECTION 2. HISTOIRE DU DROIT AMÉRICAIN

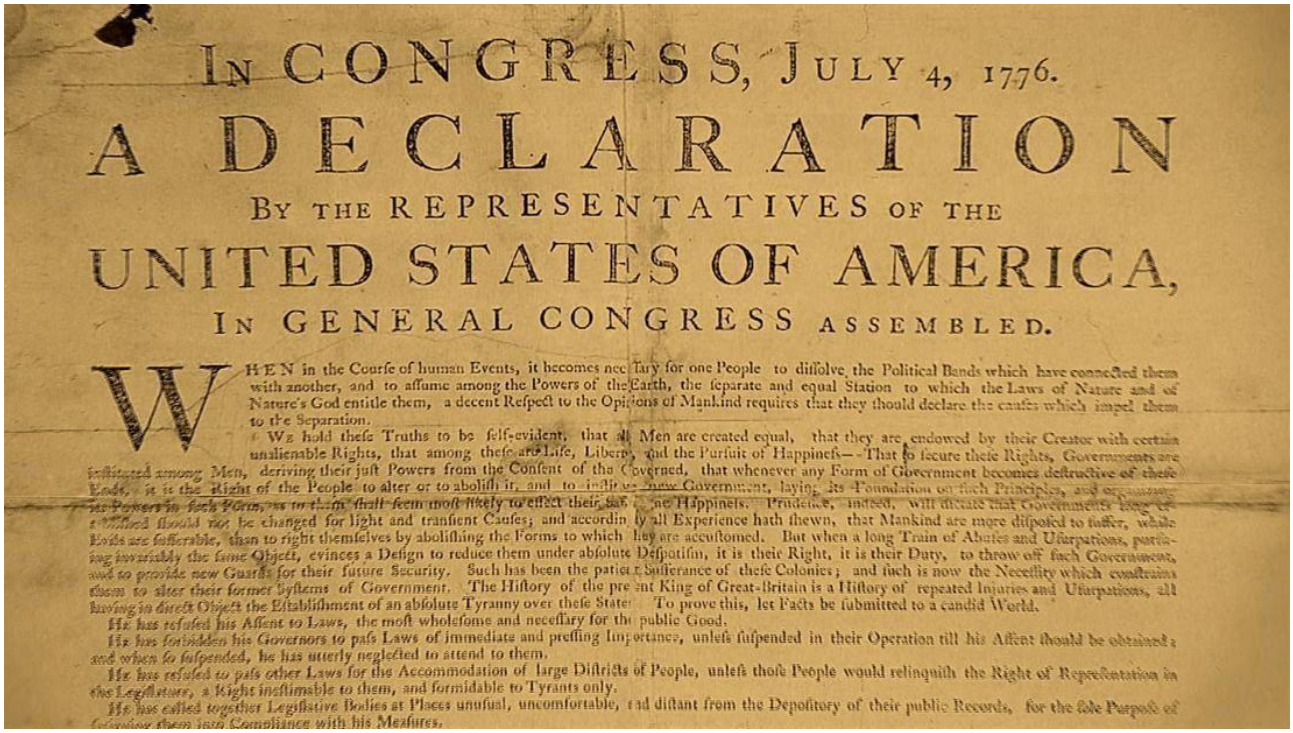
§1 : Les origines coloniales

La colonisation du territoire américain débute au **XVIIe siècle** (l'arrivée du Mayflower en 1620 en est le symbole). La première colonie anglaise est fondée à **Jameston en Virginie en 1607**. Plusieurs colonies s'établissent ensuite au Massachusetts (1629), au Maryland (1634), dans les Carolines (1663) et en Pennsylvanie (1681).

> 💡 **Remarque**
>
> Chaque colonie est fondée sur une charte octroyée par la couronne d'Angleterre — un document de nature contractuelle donnant le droit de gouverner, légiférer et rendre justice.
>
> Par la suite treize colonies se forment : **elles ont leur propre droit et Westminster légifère peu, si ce n'est en matière fiscale** (ce qui suscitera la colère des colons et le slogan "no taxation without representation").

La Déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 est consécutive à la révolte des colons contre une **nouvelle taxe sur le thé**.

> 📜 **Texte de référence**
>
> La Déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 proclame : "tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, et que parmi ces droits figurent la vie, la liberté et la recherche du bonheur."



IN CONGRESS, JULY 4, 1776.

A DECLARATION

BY THE REPRESENTATIVES OF THE

UNITED STATES OF AMERICA,

IN GENERAL CONGRESS ASSEMBLED.

WHEN in the Course of human Events, it becomes nec[essa]ry for one People to dissolve the Political Bands which have connected them with another, and to assume among the Powers of the Earth, the separate and equal Station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent Respect to the Opinions of Mankind requires that they should declare the causes which impel them to the Separation.

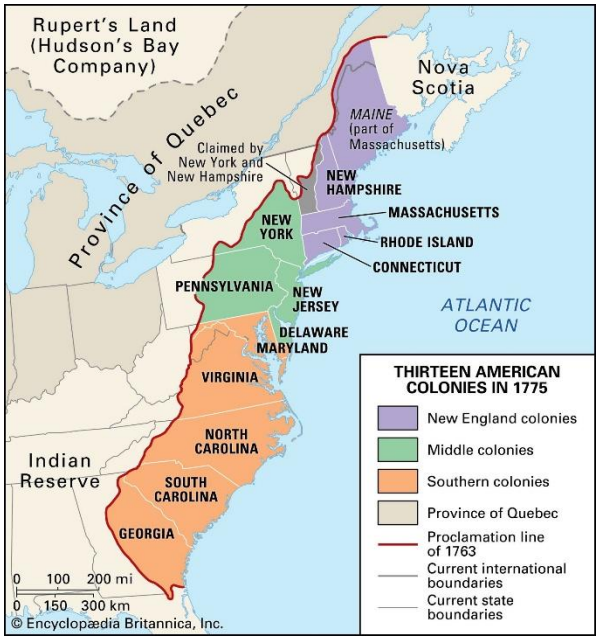
We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness—That to secure these Rights, Governments are instituted among Men, deriving their just Powers from the Consent of the Governed, that whenever any Form of Government becomes destructive of these Ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its Foundation on such Principles, and organizing its Powers in such Form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient Causes; and accordingly all Experience hath shewn, that Mankind are more disposed to suffer, while Evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the Forms to which they are accustomed. But when a long Train of Abuses and Usurpations, pursuing invariably the same Object, evinces a Design to reduce them under absolute Despotism, it is their Right, it is their Duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future Security. Such has been the patient Sufferance of these Colonies; and such is now the Necessity which constrains them to alter their former Systems of Government. The History of the present King of Great-Britain is a History of repeated Injuries and Usurpations, all having in direct Object the Establishment of an absolute Tyranny over these States. To prove this, let Facts be submitted to a candid World.

He has refused his Assent to Laws, the most wholesome and necessary for the public Good.

He has forbidden his Governors to pass Laws of immediate and pressing Importance, unless suspended in their Operation till his Assent should be obtained; and when so suspended, he has utterly neglected to attend to them.

He has refused to pass other Laws for the Accommodation of large Districts of People, unless those People would relinquish the Right of Representation in the Legislature, a Right inestimable to them, and formidable to Tyrants only.

He has called together Legislative Bodies at Places unusual, uncomfortable, and distant from the Depository of their public Records, for the sole Purpose of fatiguing them into Compliance with his Measures.



Les treize colonies adoptent leur propre constitution et leur propre déclaration de droits, et s'allient en une confédération.

Lors de la révision du traité de confédération en 1787, les États décident néanmoins de fonder une fédération, et d'adopter une **constitution fédérale.**

§2 : La Constitution fédérale de 1787

> ⚠️ **Point important**
> La Constitution fédérale de 1787 ne contenait pas de déclaration de droits à l'origine. Les États fédérés ayant adopté ces déclarations, elles furent jugées suffisantes.

La raison est d'abord celle de la compétence subsidiaire de la Fédération. Cependant, le pacte fédéral entre les gouvernants et les gouvernés suppose l'affirmation des droits de ces derniers.
Ils sont donc introduits par voie d'amendements, c'est-à-dire grâce à une **révision de la Constitution, en 1791**. Connus sous le nom de **Bill of Rights.**

> 📜 **Texte de référence**
> Le Bill of Rights (10 premiers amendements, 1791) introduit les droits fondamentaux par voie d'amendements. Ils sont complétés par la suite (XIIIe amendement 1865 : abolition de l'esclavage ; XIVe amendement 1868 : principe d'égalité).

📜 Les 10 premiers amendements (Bill of Rights, 1791)

- 🗣️ **Amendement Ier :** Liberté de religion, de parole, de presse, de réunion et de pétition.
  Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation de torts dont il se plaint.
- 🔫 **Amendement IIe :** Droit du peuple de détenir et de porter des armes (milice bien organisée).

Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, il ne sera pas porté atteinte au droit du peuple de détenir et de porter des armes.

- 🏠 **Amendement IIIe :** Interdiction du cantonnement de soldats sans consentement du propriétaire.

  Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le consentement du propriétaire, ni en temps de guerre, si ce n'est de la manière prescrite par la loi.

- 🔍 **Amendement IVe :** Protection contre les perquisitions et saisies non motivées ; exigence de mandat.

  Le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, leur domicile, leurs papiers et leurs effets contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé et il ne sera émis aucun mandat si ce n'est sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou déclaration solennelle et décrivant avec précision le lieu à perquisitionner et les personnes ou choses à saisir.

- ⚠️ **Amendement Ve :** Grand Jury, double jeopardy, droit au silence, due process, indemnisation expropriation.

  Nul ne sera tenu de répondre d'un crime capital ou infamant sans un acte de mise en accusation, spontané ou provoqué, d'un Grand Jury, sauf en cas de crimes commis pendant que l'accusé servait dans les forces terrestres ou navales ou dans la milice, en temps de guerre ou de danger public ; nul ne pourra pour le même délit être deux fois menacé dans sa vie ou dans son corps ; nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ; nulle propriété privée ne pourra être réquisitionnée dans l'intérêt public sans une juste indemnité.

- 👨‍⚖️ **Amendement VIe :** Droit à un procès rapide et public, jury impartial, confrontation des témoins, assistance d'un conseil.

  Dans toutes les poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l'État et du district où le crime aura été commis, ce district ayant été préalablement déterminé par la loi, et d'être informé de la nature et du motif de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à charge, de faire citer des témoins à sa décharge et de bénéficier du concours d'un conseil pour sa défense.

- ⚖️ **Amendement VIIe :** Droit au jury dans les procès civils dépassant 20 dollars.

  Dans les procès en common law où la valeur en litige dépasse vingt dollars, le droit au jugement par un jury sera préservé et aucun fait jugé par un jury ne sera réexaminé par un tribunal des États-Unis autrement que selon les règles de la common law.

- 🚫 **Amendement VIIIe :** Interdiction des cautions excessives, amendes excessives et châtiments cruels et inhabituels.

  Il ne sera pas exigé de caution excessive, ni imposé d'amendes excessives, ni infligé de châtiments cruels et inhabituels.

- 📋 **Amendement IXe :** L'énumération des droits dans la Constitution ne nie pas les autres droits du peuple.

  L'énumération dans la Constitution de certains droits ne saurait être interprétée comme déniant ou limitant d'autres droits conservés par le peuple.

- 🏛️ **Amendement Xe :** Les pouvoirs non délégués aux États-Unis sont réservés aux États ou au peuple.

  Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni refusés par elles aux États, sont conservés par les États respectivement ou par le peuple.

> 💡 **Remarque**
>
> La common law américaine n'est pas la common law anglaise mais les règles jurisprudentielles américaines depuis 1776. Aussi, la distinction common law/equity (voir infra) n'est pas décisive aux États-Unis. La common law anglaise a évolué dans les différents États et s'est transformée pour devenir la **common law de chaque État** (sauf en Louisiane où le système civiliste prédomine).
>
> Il existe 51 systèmes juridiques aux États-Unis.

Le droit fédéral commun général est abandonné dans la décision Erie Railway Co. v. Tompkins (1938). Il en résulte que la seule common law générale est celle existe au niveau des États (state common law), tant qu'elle est conforme à la Constitution fédérale.

Le droit privé et le droit pénal ressortissent majoritairement de la compétence des États.

§3 : Les Restatements of the Law

Les *common laws* des différents États sont néanmoins **assez proches**, et inspirent les juges des autres États.

Il existe des précédents communs tirés des principes de common law comme les **Restatements of the law** (réexposés du droit) publiés dès 1933 qui servent à exposer les règles de droit adoptées par la majorité des juges des États ainsi que les positions minoritaires.

> 📖 **Définition**
>
> *Les Restatements of the Law sont des recueils de principes juridiques compilés par l'American Law Institute (ALI) depuis 1933. Ils visent à clarifier, organiser et parfois suggérer des évolutions du common law. Bien que non contraignants, ils sont souvent cités par les tribunaux comme source persuasive.*
>
> *Ils synthétisent la jurisprudence et les doctrines dominantes dans divers domaines du droit (contrats, responsabilité civile, propriété, etc.).*

Bien qu'ils ne soient pas contraignants en eux-mêmes, les Restatements sont souvent cités par les tribunaux comme une source persuasive pour interpréter et appliquer le droit. Ils sont rédigés par des experts juridiques et mis à jour périodiquement pour refléter l'évolution des règles et des principes du common law.

§4 : La formation de la jurisprudence

Il faut également noter que la formation de la *common law* diffère aux États-Unis et au Royaume-Uni.

La jurisprudence émane ainsi de plusieurs sources :

Jurisprudence purement décisionnelle : le tribunal est appelé à trancher des affaires sur la base de décisions judiciaires antérieures (précédents). Dans les cas de droit décisionnel pur, aucune loi ou

disposition constitutionnelle ne s'applique. Ce type de droit décisionnel est ce que l'on appelle la "doctrine créée par les juges".

Historiquement, le terme "jurisprudence" fait référence à certains domaines du droit (par exemple, les délits, la propriété) qui ont commencé par être créés par les juges, ou droit décisionnel pur.

Jurisprudence fondée sur des dispositions constitutionnelles - La cour est appelée à examiner si une loi particulière ou une action gouvernementale est conforme à la Constitution des États-Unis ou à la constitution d'un État particulier. L'interprétation de la Cour peut s'appuyer sur une jurisprudence antérieure interprétant la même disposition constitutionnelle ou une autre.

Jurisprudence fondée sur des dispositions législatives - La Cour est appelée à interpréter une loi. L'interprétation de la Cour peut s'appuyer sur une jurisprudence antérieure interprétant la même loi ou une loi similaire.

Le système juridique américain reste donc ancré dans la **tradition de la *common law*** apportée d'Angleterre aux colonies nord-américaines. Cependant, on peut trouver des **traces de la tradition du droit civil** et de son importance dans les traditions juridiques des États américains.

§5 : L'influence du droit civil dans le droit américain

> 📌 **Exemple**
>
> Louisiane : système fondé sur le droit civil en raison de l'histoire française et espagnole du territoire. Californie : code civil organisé à la manière civiliste, mais contenant du common law. New York : traces de droit civil remontant à la colonisation néerlandaise (Field Code pour la procédure civile).

L'État de **Californie** a un système fondé sur la common law, mais il a codifié le droit à la manière des juridictions de droit civil. La raison de la promulgation des Codes en Californie au XIXe siècle était de **remplacer un système préexistant basé sur le droit civil espagnol par un système basé sur la common law**, similaire à celui de la plupart des autres États. Les tribunaux californiens ont traité certaines parties des Codes comme une extension de la tradition de la common law, sujette à un développement judiciaire de la même manière que la common law créée par les juges.

L'État de New York, dont l'histoire du droit civil remonte à l'époque de la **colonisation néerlandaise,** a également entrepris une codification de ses lois au **XIXe** siècle. La seule partie de ce processus de codification qui a été considérée comme complète est connue sous le nom de *Field Code*, qui s'applique à la procédure civile.

Les **colonies néerlandaises en Amérique du Nord** ont été principalement établies par la **Compagnie néerlandaise des Indes occidentales** au début du XVIIe siècle. La principale colonie était la **Nouvelle-Néerlande**, avec comme centre **Nouvelle-Amsterdam**, fondée en 1624 sur l'île de Manhattan (qui deviendra plus tard New York).

💡 **Remarque**

Expansion anglaise : Les colonies anglaises de Virginie et de la Nouvelle-Angleterre grandissaient et encerclaient progressivement la Nouvelle-Néerlande.

Prise de la Nouvelle-Néerlande (1664) : Charles II d'Angleterre, jaloux de la prospérité néerlandaise, donna l'ordre à son frère, le duc d'York (futur Jacques II), de s'emparer de la colonie. Une flotte anglaise arriva en 1664 et, sans véritable résistance, le gouverneur néerlandais Peter Stuyvesant dut capituler. La colonie fut rebaptisée **New York**.

Brève reconquête néerlandaise (1673-1674) : Les Néerlandais reprirent brièvement la ville mais la rendirent aux Anglais après la signature du Traité de Westminster (1674).

La codification d'un droit des obligations montre comment des vestiges de la tradition du droit civil à New York ont continué à exister depuis l'époque hollandaise. Il est intéressant de noter que l'influence du droit civil romain a encore sa place dans la tradition juridique américaine.

Les pères fondateurs et leurs contemporains formés au droit connaissaient non seulement les travaux de juristes anglais tels que Blackstone, mais aussi ceux des grands **juristes et théoriciens du droit civil.**

📌 **Exemples**

Thomas Jefferson, par exemple, possédait plusieurs éditions des Institutes de Justinien, et a fait l'éloge de la première édition américaine traduite de 1812, avec ses notes et annotations sur les parallèles avec le droit anglais, pour son utilité pour les juristes américains.
En effet, un exemple célèbre de son utilisation est l'affaire Pierson v. Post , en 1805.

Pierson v. Post (1805) : un juge de New York cite un principe de droit romain sur la possession d'animaux sauvages invoquée tiré des Institutes de Justinien comme précédent — illustrant la richesse historique unissant les deux traditions.

United States v. Robbins : une affaire californienne de 1926 qui a été portée devant la Cour suprême et qui a ouvert la voie aux lois modernes de l'État sur la communauté de biens. Il est question du concept de communauté de biens que la Californie a hérité non pas de la common law anglaise, mais des coutumes de l'Espagne wisigothique qui remontent au Ve siècle.

Des affaires telles que celles-ci mettent en lumière la riche histoire qui unit et divise les traditions de droit civil et de common law.

PARTIE 2 — LES SOURCES ÉCRITES

SECTION 1. LA LOI

§1. En droit anglais

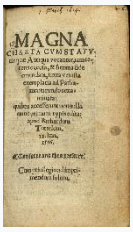
Étant donné que la principale source du droit est la common law, la loi dispose d'une fonction de correction. Lorsqu'elle intervient, elle ressemble à une décision de justice, car elle tente de prévoir toutes les éventualités avec de nombreux détails.

> 💡 **Remarque**
>
> En Angleterre, la loi est une source majeure de droit en vertu du principe de souveraineté du Parlement. Certaines lois anciennes sont encore en vigueur aujourd'hui.

Notamment en 1215, le Parlement est réuni pour la première fois pour recevoir la Magna Carta du roi Jean sans Terre.

Les textes fondateurs

1215 — Magna Carta



Charte rédigée par les barons révoltés contre Jean sans Terre. Comprend l'article 20 (proportionnalité des peines) et l'article 39 (droit à la sûreté).

Elle comprend des **articles fondateurs pour la protection des libertés**, comme l'article 20 affirmant la proportionnalité des peines, ou l'article 39 consacrant le droit à la sûreté. En Angleterre, la volonté de limiter les prérogatives royales est directement associée à la reconnaissance de droits.

1679 — Loi d'Habeas Corpus



Permet de faire produire un prisonnier devant un tribunal, d'exiger les motifs de sa détention et de le faire juger. S'applique à tous, même au roi.

Elle est votée par le Parlement et promulguée par le roi en 1679. La procédure existe déjà depuis le Moyen Âge, mais n'est assortie d'aucun moyen de contrainte.

La loi de 1679 oblige désormais à délivrer le prisonnier dès réception d'une ordonnance (writ), et en cas de refus de la part du geôlier, celui-ci peut encourir une sanction pour manque de respect dû à la cour.

1689 — Bill of Rights



Renforce les pouvoirs du Parlement et garantit des droits fondamentaux : droit de pétition, proportionnalité des peines, liberté d'expression parlementaire, immunité des parlementaires, limitation des pouvoirs du roi.

Le texte intéresse d'abord le citoyen, dont le droit de pétition est clairement affirmé. De plus, la proportionnalité des peines est consacrée, tout comme l'interdiction de traitements inhumains. Mais le Bill of Rights restreint également les pouvoirs du roi, qui ne peut plus suspendre l'application d'une loi ou ne pas appliquer une

loi. La déclaration est aussi le fondement de la liberté d'expression des parlementaires ainsi que de leur immunité.

EU **1998 — Human Rights Act**

Intègre le droit de la CEDH en droit britannique. Permet aux juges d'interpréter la loi au regard de la CEDH (section 3) et de rendre des déclarations d'incompatibilité (section 4).



La hiérarchie des normes dans l'ordre juridique britannique est déterminée par la loi ordinaire. Il en est ainsi de la hiérarchie entre le droit interne et le droit de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) : le Human Rights Act (HRA) 1998 entré en vigueur le 1er octobre 2000, crée une forme inédite de contrôle de conventionnalité des lois par rapport aux droits de la Convention.
cette loi permet au juge de déclarer les lois inconventionnelles, mais pas de les écarter de l'application du litige ou de les abroger.

💡 **Remarque : HRA**

Ce texte permet :

- Aux juges britanniques d'interpréter la loi **dans la mesure du possible** de manière compatible avec la CEDH (section 3).
- Aux tribunaux de rendre une **déclaration d'incompatibilité** (section 4) si une loi est contraire à la CEDH. Toutefois, cette déclaration n'invalide pas la loi, elle met seulement la pression sur le Parlement pour qu'il la modifie.

Ainsi :

- Les juges britanniques ne peuvent **pas annuler** une loi du Parlement (*Act of Parliament*), même si elle est contraire à la CEDH.
- Ils peuvent toutefois **écarter une règle issue du droit dérivé** (réglementations, ordonnances) si elle est incompatible avec la CEDH ou un autre traité international incorporé. Cela ne s'applique pas aux lois du Parlement.
- Si une loi est jugée incompatible, il appartient au **Parlement** de décider de la modifier ou non.

⚠️ **Point important**

Les juges britanniques ne peuvent PAS annuler une loi du Parlement (Act of Parliament), même si elle est contraire à la CEDH. Ils peuvent seulement rendre une déclaration d'incompatibilité et écarter les normes de droit dérivé (règlements, ordonnances).

EU Le droit de l'UE et le Brexit

📜 **Texte de référence**

1972 — European Communities Act (ECA)



Le droit communautaire puis européen prévalait ainsi sur toute norme britannique, même une loi, et même une loi postérieure.

Ce texte a fait l'objet d'une application remarquée dans l'arrêt Factortame (n° 2) rendu par la Chambre des Lords en 1991 (Factortame Ltd, R (On the Application Of) v Secretary of State for Transport [1990] UKHL 13, 11 octobre 1990). En l'espèce, les juges doivent résoudre un conflit entre une norme communautaire directement applicable incorporée par le European Communities Act et une loi postérieure à celle-ci. Les Law Lords concluent à l'application de la norme communautaire, et donc à la mise à l'écart d'une loi du Parlement, pour la première fois dans l'histoire du Royaume-Uni.

2018 — EU Withdrawal Act



Le texte est promulgué le 26 juin 2018 et abroge le ECA 1972. Sa section 13 crée un mécanisme ad hoc d'autorisation parlementaire de l'accord de retrait.

Le European Union (Withdrawal) Act 2018 a mis fin à la primauté du droit de l'UE au Royaume-Uni après le Brexit. Désormais, les juges britanniques ne peuvent plus écarter une loi britannique sur la base du droit de l'UE, sauf si une disposition spécifique du droit post-Brexit le permet.

💡 **Remarque**

La loi ordinaire détermine donc la hiérarchie des normes, mais aussi les règles d'introduction du droit international en droit interne (le Royaume-Uni étant un régime dualiste) ou les rapports avec les organisations internationales. Le Brexit a donc pu être concrétisé par plusieurs lois ordinaires.

🏛 La hiérarchie des normes dans l'ordre britannique

La loi ordinaire régit également le **droit constitutionnel institutionnel** :

💡 **Remarque**

- **Le droit constitutionnel matériel** s'intéresse aux **principes fondamentaux** qui structurent l'État, peu importe où ils sont inscrits.
- **Le droit constitutionnel institutionnel** porte sur **l'organisation concrète des pouvoirs publics** et leur fonctionnement.

Les deux sont complémentaires : le droit institutionnel définit les structures, tandis que le droit matériel en établit les valeurs et les principes.

Les **régions** ont des compétences importantes qui font régulièrement l'objet de controverses :

> 📌 **Exemple**
>
> Le droit à l'avortement n'est pas considéré comme un droit fondamental au Royaume-Uni, mais est régi par le droit pénal, et en Irlande du Nord le droit à l'avortement est plus strictement encadré que sur le reste du territoire.

Finalement, le rôle de la loi ordinaire pour créer du droit constitutionnel matériel est essentiel, surtout à partir de 1997 lorsque les gouvernements travaillistes successifs ont enclenché un mouvement majeur de réforme constitutionnelle.

Source du droit constitutionnel britannique	Définition	Exemple
Les lois du Parlement (Statute Law)	Lois adoptées par le Parlement pouvant avoir une portée constitutionnelle. Elles constituent la principale source écrite du droit constitutionnel britannique.	Human Rights Act 1998 ; Fixed-term Parliaments Act 2011
Les conventions constitutionnelles	Règles non écrites issues de la pratique politique et respectées par tradition. Elles ne sont généralement pas juridiquement contraignantes mais sont politiquement obligatoires.	Le Premier ministre doit disposer de la confiance de la Chambre des communes ; le roi agit sur les conseils du gouvernement.
La common law	Ensemble des principes dégagés par les décisions des tribunaux. La jurisprudence contribue à façonner les règles constitutionnelles.	Décisions judiciaires relatives aux prérogatives royales ou au contrôle de l'action du gouvernement.
Les ouvrages d'autorité (facultatif)	Écrits de juristes reconnus qui servent de référence pour interpréter les règles constitutionnelles.	Les travaux de Albert Venn Dicey sur la souveraineté du Parlement et l'État de droit.

🕮 L'Interpretation Act 1978

Les textes écrits sont soumis à des **règles d'interprétation strictes**. L'interprétation littérale doit être privilégiée par les juges.

Critères	Contenu de la règle
Définitions légales standardisées	La loi fournit des définitions uniformes pour les termes fréquemment employés dans la législation britannique.
Notion de « Person »	Le terme « person » inclut les personnes physiques ainsi que les personnes morales (entreprises, associations, collectivités, etc.).
Notion de « Month »	Le terme « month » désigne un mois calendaire, sauf disposition contraire.
Notion de « Writing »	Le terme « writing » englobe les différentes formes d'écriture, y compris l'impression et certaines formes de communication électronique.
Entrée en vigueur des lois	Une loi entre en vigueur dès la Royal Assent, sauf si une date d'application différente est prévue par le texte.
Effets de l'abrogation	L'abrogation d'une loi n'affecte pas les actes, droits ou obligations acquis sous l'empire de cette loi, sauf disposition contraire.
Principe de continuité des lois	Une loi modifiée demeure juridiquement la même loi, sauf si le législateur prévoit expressément une rupture.
Interprétation des genres	Les références au masculin incluent le féminin et inversement, sauf indication contraire du texte.
Interprétation des nombres	Le singulier inclut le pluriel et le pluriel inclut le singulier, sauf volonté contraire du législateur.
Objectif général	Assurer une interprétation cohérente et uniforme de l'ensemble des textes législatifs britanniques.

> 💡 **Remarque**
>
> *La "règle d'or" en matière d'interprétation : une interprétation littérale absurde ou incohérente doit être revue. L'interprétation littérale reste toutefois à privilégier.*

§2. En droit américain

La loi a une place plus importante aux États-Unis qu'au Royaume-Uni.

Les **lois fédérées** sont nombreuses, en raison des compétences étendues des États, notamment en **matière civile et pénale**. Une trop grande disparité législative entre les États est évitée grâce à l'adoption de modèles, tels que le Code uniforme de commerce.

En outre, la **loi fédérale** votée par le Congrès tient une place importante en raison de l'interprétation extensive de la compétence fédérale par la Cour suprême.

🏛 La Commerce Clause

📖 **Définition**

Article 1er, Section 8, alinéa 3 de la Constitution : "Le Congrès aura le pouvoir de réglementer le commerce avec les nations étrangères, entre les divers États, et avec les tribus indiennes."

📌 **Exemple**

Gibbons v. Ogden (1824) : fondement d'une compétence large du Congrès en matière économique.

Swift and Company v. United States (1905) : le Congrès peut réglementer le commerce local s'inscrivant dans un "courant" continu de commerce de commerce impliquant la circulation interétatique de biens et de services.

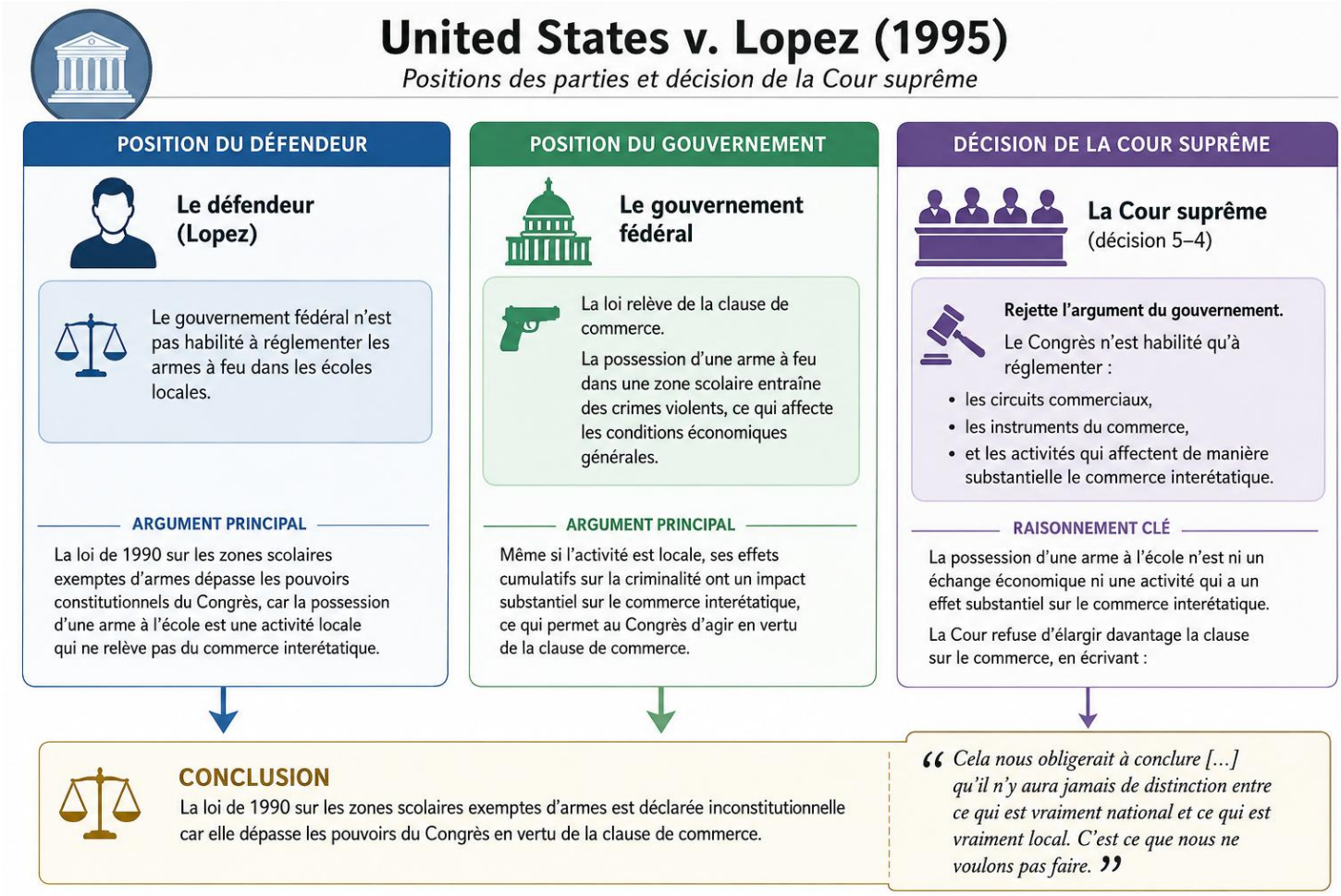
Le Congrès a souvent utilisé la clause de commerce pour justifier l'exercice d'un pouvoir législatif sur les activités des États et de leurs citoyens, ce qui a donné lieu à une controverse importante sur l'équilibre des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les États. Historiquement, la clause sur le commerce a été considérée à la fois comme un octroi de pouvoirs au Congrès et comme une restriction du pouvoir réglementaire des États.

En 1927, le Congrès a adopté des lois limitant la vente et la possession d'armes à feu, ce qui constitue une mise en œuvre controversée de ses pouvoirs implicites.

Bien que ces lois semblent en contradiction avec le deuxième amendement garantissant le droit de "garder et de porter des armes", le Congrès a toujours invoqué son pouvoir explicite de réglementer le commerce interétatique qui lui est conféré par la **clause de commerce pour justifier l'adoption de lois sur le contrôle des armes à feu.** La clause de commerce a également été invoquée pour justifier l'adoption de la première loi fédérale sur le **salaire minimum en 1938**.

⚖️ **Jurisprudence clé : armes à feu**

United States v. Lopez (514 U.S. 549 — 1995) : le défendeur était accusé d'avoir transporté une arme de poing à l'école en violation de la loi fédérale de 1990 sur les zones scolaires exemptes d'armes.



⚖️ **Jurisprudence clé : marijuana**

Gonzales v. Raich (545 U.S. 1 — 2005) : la Cour réaffirme une interprétation plus libérale de la clause de commerce en confirmant la validité de la réglementation fédérale de la production de marijuana à l'intérieur d'un État.

La doctrine des pouvoirs implicites

📖 **Définition**

Les "implied powers" s'appliquent aux pouvoirs exercés par le Congrès qui ne lui sont pas expressément accordés par la Constitution, mais qui sont jugés "nécessaires et appropriés" pour mettre en œuvre efficacement les pouvoirs accordés.

⚖️ **Jurisprudence clé**

McCulloch v. Maryland (1819) — Chief Justice John Marshall : la Cour consacre la doctrine des pouvoirs implicites. La création d'une banque nationale était constitutionnelle car liée au pouvoir du Congrès de percevoir des impôts, d'emprunter et de réglementer le commerce interétatique.

SECTION 2. LE RÈGLEMENT

§1 : En Angleterre — La législation secondaire

En Angleterre, les mesures réglementaires sont appelées "législation secondaire" (secondary legislation) ou droit dérivé, car elles découlent d'une loi (primary legislation).

> 📖 **Définition**
> *La législation secondaire est un texte édicté par les ministres en vertu des pouvoirs conférés par une loi du Parlement. Elle complète les détails des lois (législation primaire) et peut fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions.*

Elle est utilisée pour compléter les détails des lois (législation primaire). Ces détails fournissent des **mesures pratiques** qui permettent à la loi d'être appliquée. Le droit dérivé peut aussi être utilisé pour fixer la date à laquelle les dispositions d'une loi entreront en vigueur ou pour modifier des lois existantes.

Les **Statutory Instruments (SI)** sont le type de législation secondaire **le plus fréquemment utilisé** (environ 3 500 par an, dont 1 000 environ examinés par le Parlement).

> 💡 **Remarque**
> Le nombre de règlements adoptés est croissant, particulièrement lors des périodes de crise. La crise sanitaire de 2020 est particulièrement révélatrice.

> 📌 **Exemple**
> **Public Health (Control of Disease) Act 1984** : autorise des mesures réglementaires contre les épidémies.
> **Civil Contingencies Act 2004** : mesures d'urgence en cas de menace grave de santé publique.
> **Coronavirus Act 2020** : pouvoirs élargis pour faire face à la Covid-19 (morgues, personnel médical, isolement, visioconférence judiciaire, interdiction de rassemblements).

§2 : Aux États-Unis — Les Executive Orders

Aux États-Unis, le **pouvoir réglementaire présidentiel** fait l'objet de controverses.

Les executive orders ne **sont pas expressément prévus par la Constitution fédérale**.

> 📖 **Définition**
> *Un executive order est une directive signée, écrite et publiée par le président des États-Unis, qui gère les opérations du gouvernement fédéral. Non expressément prévus par la Constitution fédérale.*

Les Executive orders relevant des pouvoirs propres du Président

Constitution, section 1, article 2
Se limite à énoncer que "*le pouvoir exécutif sera confié à un président des États-Unis d'Amérique" et la section 3 dispose notamment qu'"il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et commissionnera tous les fonctionnaires des États-Unis*".

Les **Executive Orders** qui ne sont pas fondés sur une délégation du **Congrès** relèvent principalement du **pouvoir propre du président**, qui découle directement de la **Constitution américaine** (Article II).

Domaine d'intervention (pouvoir propre du président)	Exemple d'Executive Order	Justification constitutionnelle
Affaires étrangères et politique extérieure	**Executive Order 13769 (2017)** – Donald Trump : restriction de l'entrée aux États-Unis pour certaines nationalités.	Le président dispose de pouvoirs constitutionnels en matière de diplomatie, d'immigration et de sécurité nationale.
Commandement des forces armées (Commander-in-Chief Powers)	**Executive Order 9066 (1942)** – Franklin D. Roosevelt : internement des Japonais-Américains pendant la Seconde Guerre mondiale.	Le président exerce son pouvoir constitutionnel de commandant en chef des forces armées.
Organisation et fonctionnement de l'administration fédérale	**Executive Order 9835 (1947)** – Harry S. Truman : création d'un programme de vérification de loyauté des fonctionnaires fédéraux afin d'identifier les sympathisants communistes.	Le président dirige le pouvoir exécutif et peut organiser le fonctionnement de ses services administratifs.
Application des lois existantes	**Executive Order 13672 (2014)** – Barack Obama : interdiction des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les contrats fédéraux.	Le président peut interpréter et mettre en œuvre les lois fédérales de manière conforme à la Constitution et aux principes d'égalité.

Les Executive orders par délégation du Congrès

Les Executive Orders pris sur la base d'une délégation du Congrès servent à préciser, organiser ou administrer une loi déjà adoptée. Ils interviennent donc dans le domaine **réglementaire**, qui concerne :

- L'exécution et l'interprétation des lois fédérales
- L'organisation des agences gouvernementales
- La définition de règles applicables aux administrations et parfois aux entreprises en lien avec l'État

Domaine d'intervention (délégation du Congrès)	Exemple d'Executive Order	Fondement législatif et contenu
Exécution et interprétation des lois fédérales	**Executive Order 11246 (1965)** – Lyndon B. Johnson : non-discrimination dans les contrats fédéraux.	Fondé sur la **Federal Property and Administrative Services Act (1949)**. Il impose aux entreprises titulaires de contrats fédéraux des obligations en matière d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations.
Organisation des agences gouvernementales et gestion des informations sensibles	**Executive Order 13526 (2009)** – Barack Obama : classification des documents secrets.	Fondé sur des lois du Congrès relatives à la sécurité nationale. Il définit les règles applicables aux agences fédérales pour la classification, la protection et la gestion des informations sensibles.

Caractéristiques générales des Executive Orders fondés sur une délégation du Congrès :

Fonction	Description
Exécution et interprétation des lois fédérales	Préciser les modalités d'application d'une loi adoptée par le Congrès.
Organisation des agences gouvernementales	Structurer le fonctionnement interne des administrations fédérales et coordonner leur action.
Édiction de règles administratives	Définir des obligations applicables aux administrations fédérales et, dans certains cas, aux entreprises en relation avec l'État fédéral.

D'autres documents présidentiels sont parfois similaires aux executive orders dans leur format, leur formalité et leur contenu, mais ont des **objectifs différents.**

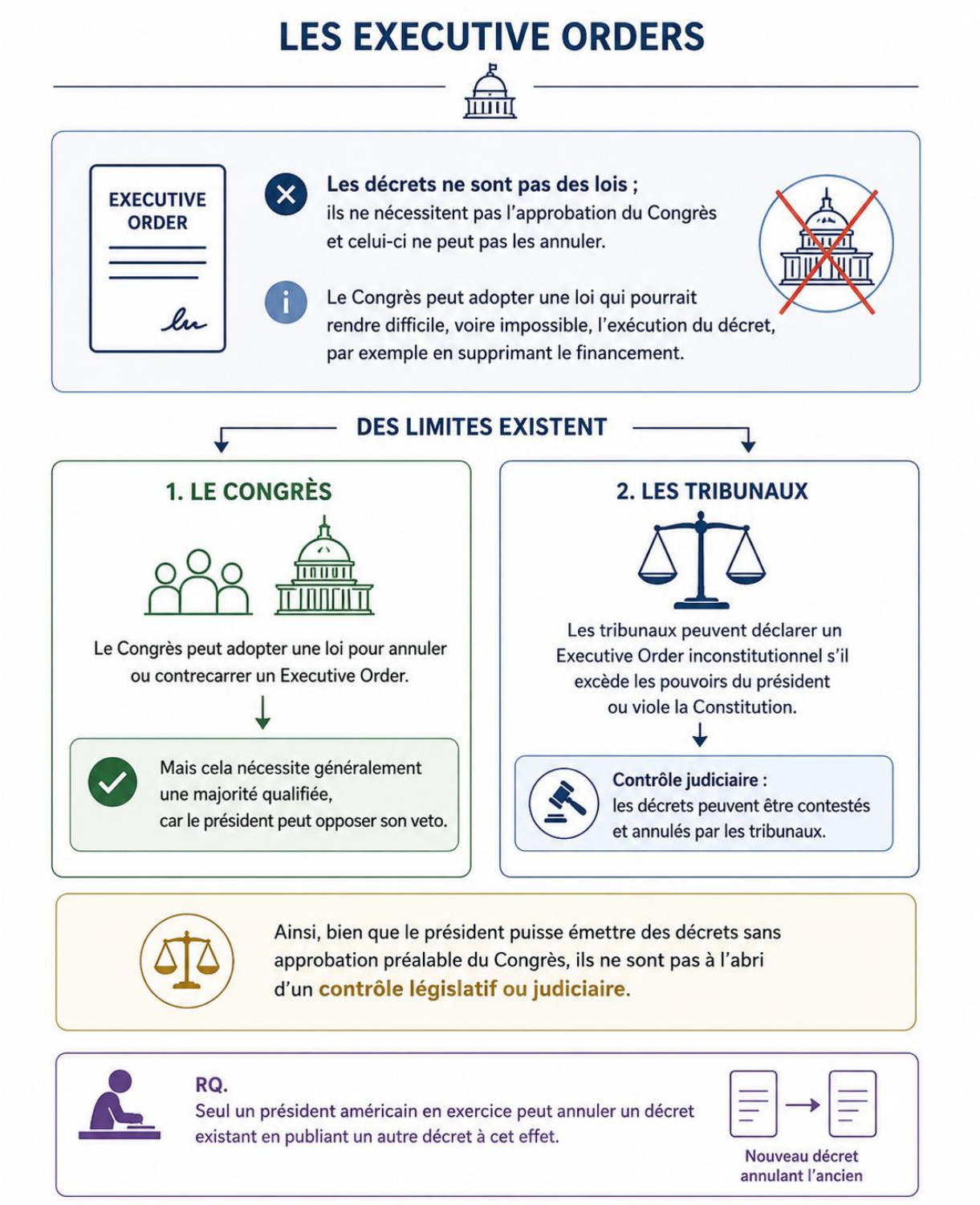
Les **proclamations**, qui sont également signées et numérotées consécutivement, communiquent des informations sur les cérémonies officielles.

Les **ordres administratifs** - par exemple, les mémos, les avis, les lettres, les messages - ne sont pas numérotés, mais sont tout de même signés, et sont utilisés pour gérer les questions administratives du gouvernement fédéral.

Les trois types de documents présidentiels - ordres exécutifs, proclamations et certains ordres administratifs - sont publiés dans le **Federal Register**, le journal quotidien du gouvernement fédéral visant à informer le public des réglementations et des actions fédérales. Ils sont également catalogués par les Archives nationales en tant que documents officiels produits par le gouvernement fédéral.

⚠️ **Point important**

Les executive orders ne sont pas des lois et ne nécessitent pas l'approbation du Congrès. Toutefois, le Congrès peut adopter une loi pour les contrecarrer et les tribunaux peuvent les déclarer inconstitutionnels. Seul un président en exercice peut annuler un executive order existant.



PARTIE 3 — LE PRÉCÉDENT

Le terme "précédent" fait référence à une décision de justice qui fait autorité pour trancher des affaires ultérieures impliquant des faits identiques ou similaires, ou des questions juridiques similaires.

> 📖 **Définition**
> *Le stare decisis ("s'en tenir aux choses décidées") exige des tribunaux qu'ils appliquent la loi de la même manière à des cas présentant les mêmes faits. Il garantit que les personnes en situations similaires soient traitées de la même manière, indépendamment de l'opinion personnelle d'un juge.*

SECTION 1. EN ANGLETERRE

§1 : Principe

La prédominance du droit non-écrit

La common law est caractérisée par la **prédominance du droit non-écrit**, ce qui est renforcé par l'absence de constitution écrite.

> 💡 **Remarque**
> Cette particularité de la constitution britannique a été mise en lumière par Dicey : aucun texte écrit ne peut être aussi utile que la jurisprudence pour résoudre un litige. Aucun texte ne peut accorder plus de droits aux individus que ne le fait déjà la common law.
> **Albert Venn Dicey** (né le 4 février 1835 et mort le 7 avril 1922) est un juriste britannique, théoricien des lois constitutionnelles. Les principes qu'il expose dans son œuvre majeure *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (1915).

La méthode de la common law est originale, car la **règle du stare decisis** impose de respecter les précédents.

> 📖 **Définition**
> *Le stare decisis, qui signifie en latin "s'en tenir aux choses décidées", est une doctrine judiciaire selon laquelle un tribunal suit les principes, les règles ou les normes de ses décisions antérieures (ou des décisions de tribunaux supérieurs) lorsqu'il statue sur une affaire dont les faits peuvent être considérés comme similaires. L'expression latine complète est : "stare decisis et non quieta movere" — s'en tenir à la chose décidée et ne pas troubler le calme.*

Le droit non-écrit est ainsi marqué par l'importance de la jurisprudence et de la règle du précédent. Cette règle est apparue au **XIXe siècle** afin de garantir la sécurité juridique. La théorie des précédents

permet de donner un caractère de certitude à un système où les pouvoirs du juge auraient pu conduire à l'arbitraire.

Ce principe postule qu'une règle de droit énoncée dans une décision de justice s'impose aux juges à l'occasion de faits semblables. Lorsque les faits sont analogues, un juge peut toutefois estimer qu'il n'est pas lié par le précédent lorsque la règle énoncée n'est pas le motif déterminant de la décision ou **ratio decidendi** (the reason for deciding).

Les précédents ne peuvent en outre émaner que des juridictions supérieures.

> 🕮 **Définition — *Ratio decidendi***
> Partie essentielle de la décision qui crée un précédent juridiquement contraignant. C'est la règle de droit sur laquelle repose la décision du tribunal.

Les deux formes du stare decisis

En général, les tribunaux appliquent le principe du stare decisis de l'une des deux manières suivantes :

- **Stare decisis horizontal :** les tribunaux appliquent le précédent en adoptant la même position juridique que celle que le tribunal a précédemment adoptée dans une affaire antérieure.
- **Stare decisis vertical :** les tribunaux appliquent également les décisions des tribunaux supérieurs ayant une compétence de contrôle.

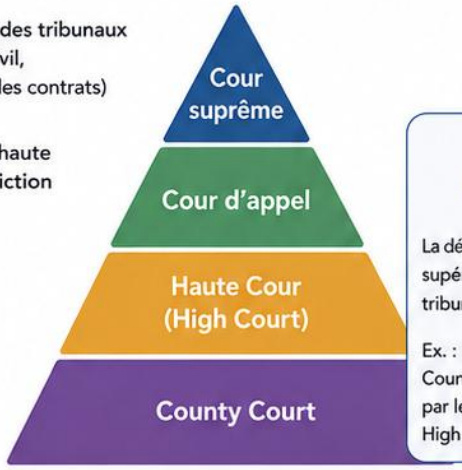
§2 : Application

LA THÉORIE DU STARE DECISIS DANS LE SYSTÈME JUDICIAIRE BRITANNIQUE

1 La décision d'un tribunal supérieur s'impose à un tribunal inférieur

Hiérarchie des tribunaux (en droit civil, ex. : droit des contrats)

Plus haute juridiction



Plus bas niveau

La décision d'un tribunal supérieur lie les tribunaux inférieurs.

Ex. : les juges de la County Court sont liés par les décisions de la High Court.

2 La Cour d'appel est liée par ses propres décisions antérieures en matière civile (stare decisis horizontale, mais seulement pour elle)

Établi dans l'affaire *Young v. Bristol Aeroplane Co.* [1944]
La **Cour d'appel est liée par sa propre décision passée, à trois exceptions près :**

1 Conflit avec une décision ultérieure de la Chambre des Lords (aujourd'hui Cour suprême)

La Cour d'appel doit suivre la Chambre des Lords.

La Cour d'appel est liée par les décisions antérieures de la Chambre des Lords.

Ex. : *Re Selectmove* [1993] – la Cour d'appel s'estime liée par *Foakes v. Beer* (1884), décision de la Chambre des Lords, même si elle est en désaccord.

2 Existence de deux décisions antérieures contradictoires de la Cour d'appel

La Cour d'appel ultérieure doit choisir entre les deux dans un troisième cas.

3 Décision antérieure rendue *per incuriam* (c'est-à-dire ignorée par erreur une règle de droit ou un précédent contraignant)

La Cour d'appel ultérieure n'est pas tenue de suivre sa décision antérieure.

Per incuriam : dans le système judiciaire britannique, une décision rendue *per incuriam* signifie qu'elle a été prise par inadvertance ou par erreur, en ignorant une règle de droit clairement établie ou un précédent contraignant.

3 En ce qui concerne les autres tribunaux, la décision d'un tribunal de même degré n'a pas une autorité absolue, mais relative

- Les juges des tribunaux de première instance ne sont pas tenus de suivre les décisions des juges de la même cour.
- Ils sont seulement tenus de suivre les décisions de la Cour d'appel et de la Chambre des Lords (ou Cour suprême).

Même à ce niveau, la certitude est importante et les juges suivent généralement les décisions antérieures des juges du même niveau.

Colchester Estates v. Carlton Industries [1986] : lorsqu'il existe deux décisions conflictuelles rendues par des juges de la High Court, la décision la plus récente doit être suivie, à condition qu'elle ait été prise après un examen approfondi de la décision antérieure.

4 La Chambre des Lords (puis la Cour suprême) est normalement liée par ses propres décisions

Traditionnellement, la Chambre des Lords est liée par ses propres décisions passées (*London Tramways v. London County Council* [1898]).
La règle s'appliquait même si une Chambre des Lords ultérieure n'était pas satisfaite des conséquences de sa propre décision passée.

La Court suprême, en tant que plus haute juridiction, suit le même principe de continuité et de stabilité jurisprudentielle.

⚠ **Évolution majeure : le Practice Statement de 1966**

Depuis 1966, la position a changé. Les Lords reconnaissent qu'une adhésion trop rigide aux précédents peut entraîner une injustice dans un cas particulier et restreindre indûment le développement approprié du droit. **Ils se proposent donc de modifier leur pratique actuelle** et, tout en considérant les décisions formelles de cette chambre comme normalement contraignantes, **de s'écarter d'une décision antérieure lorsqu'il semble juste de le faire**.

À cet égard, ils garderont à l'esprit le danger de perturber rétrospectivement la base sur laquelle les contrats, les règlements de propriété et les arrangements fiscaux ont été conclus, ainsi que le besoin particulier de certitude en matière de droit pénal. Cette annonce n'est pas destinée à affecter l'utilisation du précédent ailleurs que dans cette Chambre.

Depuis 1966, la Chambre a la faculté de s'écarter d'une décision antérieure dans les conditions suivantes :

1. La décision antérieure est erronée, ET
2. Le prononcé d'une décision différente dans le présent ne compromettra pas les relations économiques (ou autres) instaurées conformément à la décision antérieure.

Depuis 1966, la Chambre des Lords ne s'est écartée de ses propres décisions antérieures que très rarement.

§3 : Les recueils de jurisprudence

La référence à ces décisions est facilitée par un système de recueil. Les comptes rendus juridiques ont été régularisés à la fin du XIXe siècle.

💡 **Remarque**

Avant 1865, les avocats assistaient aux audiences et rédigeaient et publiaient des rapports sur les affaires, souvent sous leur propre nom. Ces rapports sont généralement appelés « **rapports nominatifs** » (nominate reports).

Ils désignent des collections de décisions judiciaires publiées par des **particuliers ou des éditeurs privés** avant l'établissement des séries officielles de rapports juridiques.

Ces rapports étaient souvent nommés d'après leurs auteurs ou éditeurs, comme Coke's Reports ou Blackstone's Reports. Ils couvraient les décisions des tribunaux anglais entre le 16e et le 19e siècle. La prolifération de ces rapports et l'incertitude quant à ce qui constituait le jugement faisant autorité ont conduit à la création de l'Incorporated Council of Law Reporting (ICLR) qui publie les Official Law Reports. De nombreux rapports plus anciens ont été rassemblés et publiés en 172 volumes sous le nom d'English Reports.

La prolifération de ces rapports et l'incertitude quant à ce qui constituait le jugement faisant autorité ont conduit à la création de **l'*Incorporated Council of Law Reporting* (ICLR) qui publie les *Official Law Reports***.

De nombreux rapports plus anciens ont été rassemblés et publiés en 172 volumes sous le nom d'***English Reports***.

Environ **2 500 jugements** (moins de 2 % de tous les jugements) sont rapportés dans les séries de **Law Reports** chaque année. Les décisions de la Cour suprême (anciennement Chambre des Lords) et de la Cour d'appel prédominent en raison du poids que leur accorde la doctrine du précédent. Seule une petite partie des milliers d'affaires de première instance devant la High Court sont rapportées.

📜 **Les Law Reports — critères d'inclusion**

Les Law Reports incluent théoriquement toutes les affaires qui :

- introduisent, ou semblent introduire, un nouveau principe ou une nouvelle règle ;
- modifient matériellement un principe ou une règle existants ;
- règlent, ou tendent matériellement à régler, une question sur laquelle le droit est douteux ;
- pour quelque raison que ce soit, sont particulièrement instructives.

Les juges peuvent recommander des décisions à rapporter, mais cette décision est généralement prise par les éditeurs des différentes séries de recueils de jurisprudence. Cela signifie que des cas d'intérêt spécialisé peuvent être négligés, tandis que des cas qui n'apportent rien de nouveau mais donnent l'impression d'être largement couverts peuvent être inclus.

§3. La construction des décisions de justice

La règle du précédent se traduit par une construction particulière des décisions de justice, qui comportent :

- Un exposé détaillé des faits du litige *(statement of the facts of the case)* ;
- L'énumération des différentes lois et précédents qui semblent pertinents en l'espèce *(relevant to the case)* ;
- L'énonciation de la règle de droit paraissant s'appliquer *(applicable to the case)* et appliquée en l'espèce.

📖 **Définition — Ratio decidendi**

La ratio decidendi consiste en la partie la plus fondamentale du jugement, celle dans laquelle le juge donne les motifs de sa décision et la règle de droit qu'il a suivie. La ratio decidendi renvoie ainsi à l'ensemble des déclarations et motifs nécessaires pour donner une solution au litige. **Elle est contraignante et doit être suivie par les tribunaux inférieurs.**

📖 **Définition — Obiter dicta (obiter dictum au singulier)**

En droit britannique, un dicta désigne une remarque ou une observation faite par un juge dans une décision judiciaire qui ne constitue pas une règle de droit contraignante. Ces commentaires sont émis en marge de la décision principale et n'ont pas de valeur de précédent obligatoire (binding precedent), contrairement à la ratio decidendi.

Même s'ils ne sont pas contraignants, les obiter dicta peuvent : (1) orienter les juges dans des affaires futures en suggérant des interprétations du droit ; (2) influencer l'évolution de la jurisprudence ; (3) donner des indications sur des réformes possibles en mettant en lumière des lacunes dans la loi.

Cette affaire illustre la distinction fondamentale entre ratio decidendi et obiter dicta.

⚖️ R v Howe [1987] AC 417 — Chambre des Lords	
📝 Faits	Les accusés (Howe et ses complices) avaient participé à des meurtres sous la contrainte d'un tiers, qui les avait menacés de mort s'ils ne suivaient pas ses ordres. Ils ont été poursuivis pour meurtre et ont tenté de se défendre en invoquant la contrainte (duress), c'est-à-dire qu'ils n'avaient agi que parce qu'ils étaient eux-mêmes sous la menace d'une mort imminente.
❓ Question	La défense de la contrainte (duress) peut-elle être invoquée pour un crime de meurtre ?
🏛️ Décision	NON. La Chambre des Lords a jugé que la contrainte n'est pas une défense valable pour le meurtre, même si l'accusé agit sous la menace de mort. Raisonnement : (1) Le meurtre est si grave que la loi ne peut permettre d'y échapper simplement parce qu'on a été forcé de tuer ; (2) Principe : « mieux vaut mourir que tuer une personne innocente » ; (3) Cette interdiction s'applique autant au meurtrier principal qu'à l'aide ou complice.
☑️ Ratio decidendi	La défense de la contrainte (duress) ne peut pas être invoquée comme excuse pour un meurtre. Cette règle a un effet obligatoire pour les tribunaux inférieurs au Royaume-Uni.

💡 **Remarque**
En obiter dictum, la Chambre des Lords a également suggéré que cette défense ne devrait pas être acceptée pour une tentative de meurtre, bien que ce point n'ait pas été directement en cause dans l'affaire.

⚖️ **R v Gotts [1992] 2 AC 412 — L'obiter dictum devient précédent**
Dans l'affaire R v Howe [1987] AC 417, la Chambre des Lords a statué en obiter dictum que la défense de la contrainte ne devrait pas non plus être acceptée pour une tentative de meurtre. **Plus tard, cette remarque a influencé R v Gotts [1992] 2 AC 412**, où la Chambre des Lords a effectivement refusé la défense de la contrainte pour la tentative de meurtre. Ce qui était un obiter dictum dans Howe est devenu un nouveau précédent contraignant dans Gotts.

Décision récente en matière de droit des personnes, rendue par la Cour suprême du Royaume-Uni le 15 décembre 2021.

⚖️ R (Elan-Cane) v. Secretary of State for the Home Department [2021] UKSC 56 Cour suprême du Royaume-Uni — 15 décembre 2021	
📝 Faits	Christie Elan-Cane, une personne non genrée, a contesté la politique du gouvernement britannique de ne pas offrir une option de genre « X » sur les passeports, soutenant que cela violait son droit au respect de la vie privée en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
❓ Question	La politique gouvernementale d'exclusion d'une option de genre « X » sur les passeports est-elle illégale au regard de l'article 8 de la CEDH ?
🏛️ Décision	La Cour suprême a statué que la politique actuelle du gouvernement n'était pas illégale, estimant que l'absence d'une option de genre « X » sur les passeports était justifiée dans le cadre de l'actuel système d'enregistrement du sexe au Royaume-Uni.
☑️ Ratio decidendi	L'absence d'une option de genre « X » sur les passeports britanniques ne constitue pas une violation illégale de l'article 8 de la CEDH dans le cadre du système d'enregistrement du sexe en vigueur. L'appel est rejeté.

🔄 Récapitulatif — Points clés à retenir

☑️ Le précédent garantit la sécurité juridique et l'égalité de traitement.

☑️ Le stare decisis impose de respecter les décisions antérieures des juridictions supérieures.

☑️ La ratio decidendi est la seule partie contraignante (binding precedent) d'un jugement.

☑️ Les obiter dicta ne sont pas contraignants, mais peuvent influencer les décisions futures.

☑️ Depuis le Practice Statement de 1966, la Cour suprême peut s'écarter de ses propres précédents (rarement).

☑️ Les décisions sont publiées dans les Law Reports (ICLR) — seul un très petit nombre est rapporté chaque année.

SECTION 2. AUX ETATS-UNIS

Il existe deux types distincts de précédents que les juges prennent en considération :

- Les précédents **obligatoires ou contraignants** (*mandatory* ou *binding*).
- Les précédents **persuasifs** (*persuasive*).

> 📖 **Définition — Précédent contraignant (binding/mandatory)**
>
> *Si le précédent est contraignant, les tribunaux sont tenus de suivre ces décisions antérieures.*

📖 **Définition — Précédent persuasif (persuasive)**

Les tribunaux ne sont pas obligés de suivre les précédents persuasifs, mais ils peuvent en tenir compte pour déterminer comment les tribunaux d'autres juridictions résolvent des questions juridiques particulières.

§1. Origines du précédent persuasif

Un précédent peut être persuasif dans plusieurs situations :

1. **Décisions d'autres juridictions :** une cour peut s'inspirer d'une décision rendue dans un autre pays de common law.
2. **Décisions de tribunaux de même niveau ou inférieurs :** bien qu'elles ne soient pas contraignantes, elles peuvent être convaincantes si leur raisonnement est jugé pertinent.
3. **Opinions dissidentes :** une opinion minoritaire dans une affaire peut influencer un juge dans une affaire ultérieure.
4. **Doctrine et commentaires juridiques :** les écrits d'universitaires et d'experts en droit peuvent aussi être considérés comme des précédents persuasifs.

📌 **Exemple**

Si un tribunal en Australie doit statuer sur une question juridique nouvelle et qu'aucun précédent obligatoire ne s'applique, il peut être influencé par une décision de la Cour suprême des États-Unis ou du Royaume-Uni.
Ceci est également vrai pour d'autres sources de droit : *un tribunal d'État peut prendre en compte une loi ou un règlement fédéral pour résoudre un litige relevant du droit de l'État, mais ces lois fédérales ne constituent qu'une autorité persuasive pour le tribunal d'État.*

§2 : Les limites de la doctrine

💡 **Remarque**

La doctrine du précédent ne vaut par ailleurs que dans un État fédéré : les tribunaux ne sont pas liés par les décisions des juridictions supérieures d'un autre État.

Elle ne vaut également qu'à l'égard des décisions des **juridictions supérieures**, et non des juridictions de même niveau.

⚠️ **Point essentiel**

Les Cours suprêmes (fédérale et fédérées) ne sont pas liées par leur propre jurisprudence.

§3 : Le revirement de jurisprudence (overruling)

📖 **Définition — Overruling**

L'overruling (revirement de jurisprudence) est admis si une décision précédente est erronée. Le ***prospective overruling*** permet de dégager une règle nouvelle tout en appliquant l'ancienne, afin d'éviter les effets négatifs de la rétroactivité de la nouvelle règle.

💡 **Remarque**

Parmi les milliers de décisions qu'elle a rendues au cours de son histoire, la Cour suprême des États-Unis n'a rompu avec le stare decisis que 145 fois dans des affaires nécessitant une interprétation de la Constitution.

⚖️ **Dobbs v. Jackson Women's Health (597 U.S. (2022)) — Renversement de Roe v. Wade**

L'arrêt Dobbs v. Jackson Women's Health Organization (597 U.S. (2022)) constitue le renversement de l'arrêt ***Roe v. Wade*** (410 U.S. 113 (1973)), décision historique qui avait étendu la protection constitutionnelle de l'avortement. Il illustre ainsi un cas d'overruling explicite par la Cour suprême fédérale.

§4 : Le précédent unique

Pourtant, un seul précédent peut faire office de **règle immuable**. Dans certains cas en effet, un seul précédent peut jouer un rôle particulièrement important dans la prise de décision de la Cour.

Information des droits constitutionnels avant interrogatoire

⚖️ **Miranda v. Arizona (384 U.S. 436 (1966)) — Le précédent fondateur**

En 1966, l'arrêt Miranda v. Arizona a établi que les forces de l'ordre doivent informer les suspects de leurs droits constitutionnels avant un interrogatoire (*"Miranda warnings"* : droit au silence, droit à un avocat, etc.). Dans cette espèce, la Cour décide que le cinquième amendement à la Constitution interdit aux procureurs d'utiliser les déclarations faites par une personne lors d'un interrogatoire en garde à vue comme preuve lors de son procès, à moins qu'ils ne puissent démontrer que la personne a été informée de son droit de consulter un avocat avant et pendant l'interrogatoire, et de son droit de ne pas s'auto-incriminer avant l'interrogatoire de la police, et que le défendeur a non seulement compris ces droits mais y a également renoncé volontairement.

📜 **18 U.S.C. § 3501 — Loi fédérale de 1968**
En 1968, le Congrès a adopté 18 U.S.C. § 3501, qui stipulait que les aveux d'un suspect pouvaient être admissibles devant un tribunal tant qu'ils étaient « *volontaires* », même si la police n'avait pas donné les avertissements Miranda. Cette loi aurait remis en cause l'affaire Miranda v. Arizona de 1966.

⚖️ **Dickerson v. United States (530 U.S. 428 (2000)) — Le précédent unique**

En 2000, la Cour suprême a examiné si la loi fédérale 18 U.S.C. § 3501 pouvait annuler Miranda. **En invalidant la loi, la majorité a refusé d'annuler Miranda**, notant que l'affaire de 1966 avait été intégrée dans les pratiques policières de routine au point que les avertissements font désormais partie de la culture nationale.

Protection du discours symbolique par le premier amendement

⚖️ **Texas v. Johnson (491 U.S. 397 (1989)) — La liberté d'expression et le drapeau**

En 1984, Gregory Lee Johnson, un habitant du Texas, a brûlé un drapeau américain à l'extérieur du bâtiment de la convention nationale républicaine pour protester contre la nomination de Ronald Reagan. La police texane l'a arrêté et accusé de profanation d'un objet vénéré. Johnson a fait appel de sa condamnation, arguant que brûler un drapeau était une forme de discours symbolique, protégé par la garantie de liberté d'expression du premier amendement.
L'affaire est allée jusqu'à la Cour suprême, qui s'est prononcée en faveur de Johnson par **5 voix contre 4** le 21 juin 1989. La Cour a décidé que l'autodafé du drapeau était effectivement une forme de discours symbolique protégé par le premier amendement, jugeant que le gouvernement ne pouvait pas empêcher « *l'expression d'une idée simplement parce que la société trouve l'idée elle-même offensante ou désagréable* ».

Droit individuel de porter des armes

📜 **Le deuxième amendement de la Constitution américaine**
"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed."
Traduction : « Une milice bien réglée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de garder et de porter des armes ne doit pas être violé. »

💡 **Remarque**
Le deuxième amendement fait l'objet d'un débat houleux, deux camps s'opposant sur sa formulation et sa signification.

Certains soutiennent que les Pères fondateurs n'avaient l'intention de donner aux individus le droit de porter des armes que dans le contexte d'une milice.
D'autres interprètent l'amendement comme une autorisation générale pour tous les individus de posséder des armes, indépendamment du service militaire.

⚖️ **District of Columbia v. Heller (554 U.S. 570 (2008))**

Lorsque Dick Heller, un résident de Washington D.C., s'est vu refuser une demande de permis de possession d'une arme de poing, il a contesté les lois strictes de DC en matière de contrôle des armes à feu. En 2008, la Cour suprême lui a donné raison par **5 voix contre 4**, faisant valoir que le deuxième amendement donne aux individus le droit de posséder des armes en dehors du service militaire.
Le juge Antonin Scalia écrit : « Nous estimons que l'interdiction de la possession d'armes de poing à domicile dans le district viole le deuxième amendement, tout comme l'interdiction de rendre opérationnelle toute arme à feu légale dans la maison à des fins d'autodéfense immédiate... [Le deuxième amendement] élève assurément au-dessus de tous les autres intérêts le droit des citoyens respectueux de la loi et responsables d'utiliser des armes pour la défense du foyer et de la maison. »

§ 5 : Les facteurs d'annulation d'un précédent

La Cour suprême a déclaré qu'il doit y avoir une justification spéciale — ou, au moins, des motifs solides — qui vont au-delà du désaccord avec le raisonnement d'une décision antérieure pour annuler un précédent constitutionnel.
Lorsqu'elle décide d'annuler un précédent interprétant la Constitution, la Cour tient toujours compte de plusieurs **facteurs pragmatiques** qui visent à favoriser la primauté du droit tout en mettant en balance les coûts et les avantages pour la société :

Critère	Description
Qualité du raisonnement	La Cour peut tenir compte de la qualité du raisonnement de la décision antérieure.
Applicabilité	La Cour examine si les règles ou normes du précédent sont trop difficiles à appliquer.
Incompatibilité avec des décisions connexes	La Cour vérifie si le précédent est incompatible avec d'autres décisions sur des questions constitutionnelles similaires.
Modification de la compréhension des faits pertinents	L'évolution de la compréhension des faits par les juges et la société peut affaiblir l'autorité d'un précédent.
Fiabilité	La Cour peut maintenir un précédent si son abandon risquerait de porter préjudice aux personnes, aux entreprises, aux organisations ou aux institutions qui s'y sont appuyées.

💡 **Remarque**

Une étude des décisions de la Cour suprême appliquant ces facteurs suggère qu'il est difficile de prévoir quand la Cour annulera une décision antérieure. Cette incertitude découle, en partie, du fait que la Cour n'a pas fourni une liste exhaustive des facteurs qu'elle applique pour déterminer si une décision doit être annulée ou comment elle les pondère.

📚 **Récapitulatif — Points clés à retenir**

✅ Deux types de précédents : contraignants (binding) et persuasifs (persuasive).

✅ La doctrine du précédent ne vaut que dans un État fédéré ; les Cours suprêmes ne sont pas liées par leur propre jurisprudence.

✅ L'overruling est admis si une décision est erronée ; le prospective overruling évite les effets rétroactifs.

✅ La Cour suprême fédérale n'a rompu avec le stare decisis que 145 fois dans son histoire.

✅ Un seul précédent peut faire office de règle immuable (ex. : Miranda, Texas v. Johnson, Heller).

✅ Cinq facteurs pragmatiques guident la décision d'annuler un précédent : qualité du raisonnement, applicabilité, compatibilité, évolution des faits, fiabilité.

🏛 Focus sur la Cour suprême des États-Unis

SECTION 1. ORIGINES ET FONDEMENTS HISTORIQUES

§1. L'influence de Montesquieu

> 📖 **Définition — La puissance de juger (Montesquieu)**
>
> *L'ouvrage L'Esprit des lois de Montesquieu (1748) peut être considéré comme un tournant dans l'histoire des cours suprêmes. Montesquieu est le premier à parler d'une « **puissance de juger** » dans le chapitre sur la Constitution d'Angleterre. Cette puissance doit être exercée par des personnes tirées du corps du peuple. Pour garantir la liberté, cette puissance doit être « séparée de la puissance législative et de l'exécutrice ».*

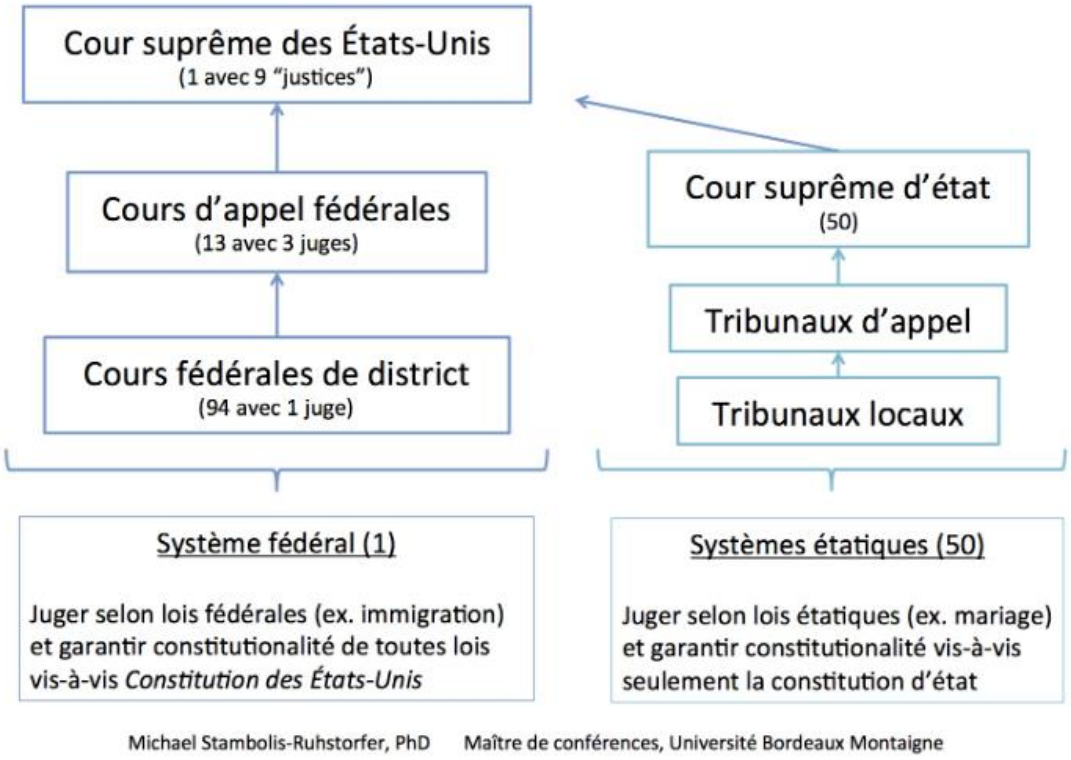
L'influence de Montesquieu sur les constituants américains a nourri les débats qui ont entouré la création et les premières années de la Cour suprême des EU. Très critiques à l'égard des juges de la Couronne britannique, les américains ont été particulièrement sensibles à l'idée de **séparer les organes judiciaires des organes exécutifs ou législatifs**.

> 💡 **Remarque**
> En même temps, les rédacteurs des nouveaux États américains avaient une conception restrictive de l'indépendance des juges qu'ils voulaient réduire à de simples machines. Entre la crainte de l'arbitraire judiciaire et celle des abus de la puissance législative, la constitution fédérale de 1787 chercha par la séparation des pouvoirs à concilier la primauté de la Constitution avec les intérêts des États.

> 📜 **Article 3 de la Constitution fédérale (1787) — Le pouvoir judiciaire**

L'article 3 confiait le « **pouvoir judiciaire** » à une Cour suprême (avec un nombre de juges indéterminés) ainsi qu'à des tribunaux inférieurs établis par le Congrès. Les compétences de ces juridictions fédérales s'étendaient :

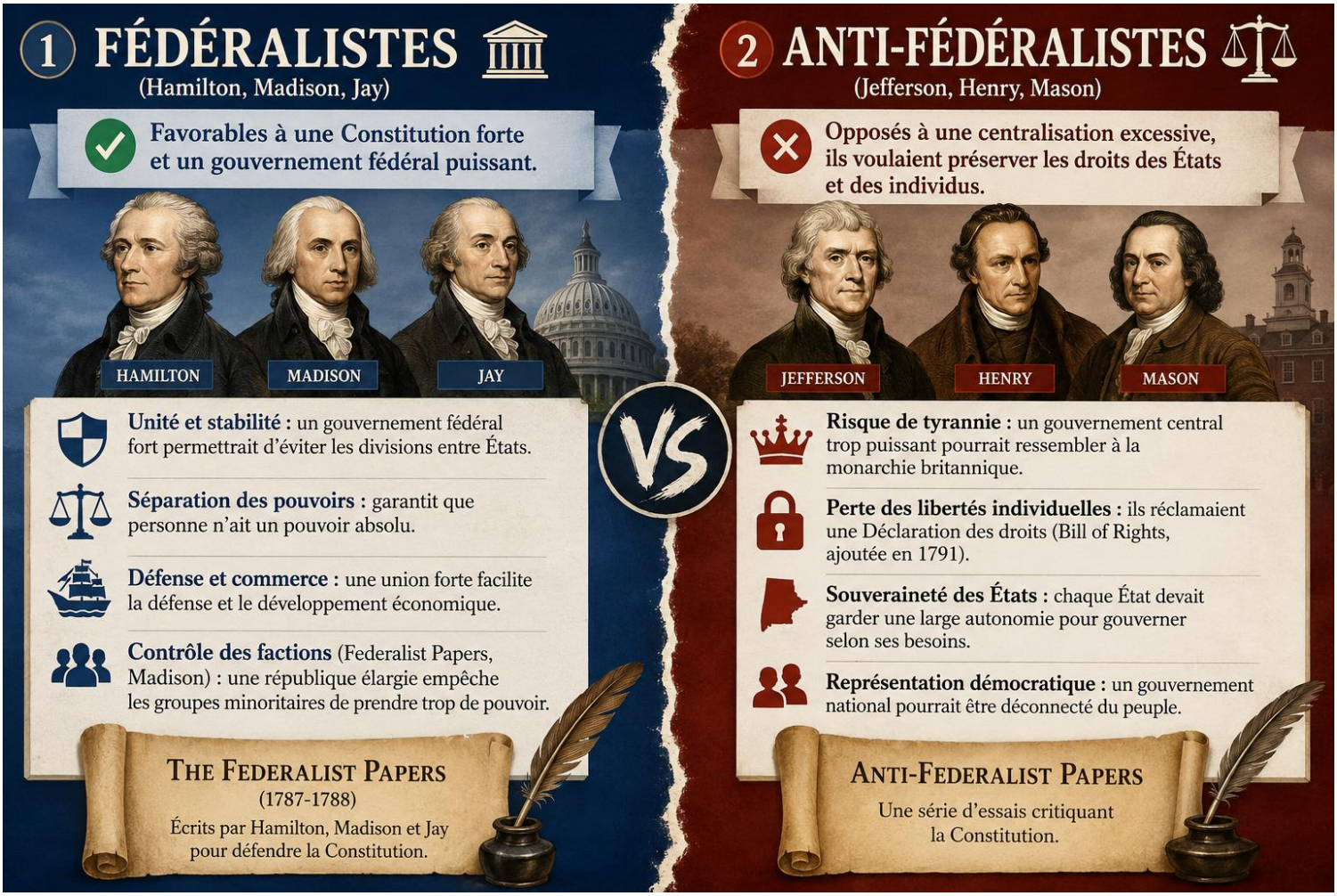
- aux questions touchant la constitution et les lois fédérales ;
- aux litiges dans lesquels les EU étaient partie ;
- aux conflits entre États fédérés ou citoyens américains de divers États ;
- aux affaires maritimes ou relatives au droit des ambassadeurs.



§ 2 : Le débat fédéralistes / anti-fédéralistes

Le laconisme des dispositions constitutionnelles donna lieu, dès les premières années de fonctionnement de la CS, à une **controverse sur le pouvoir d'interprétation de la Cour** à l'égard de la constitution et de son autorité vis-à-vis du Congrès fédéral (Sénat, Chambre des représentants).





⚠️ **Issue du débat** 🎭

✅ Les Fédéralistes ont gagné, et la Constitution a été adoptée en 1789.

✅ Les Anti-fédéralistes ont obtenu le **Bill of Rights** en 1791 pour garantir les libertés individuelles.

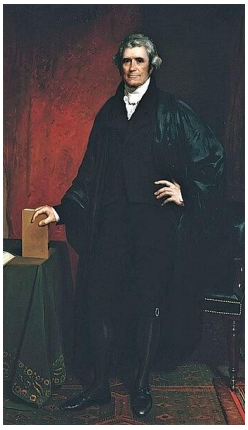
§3 : L'affaire marbury v. madison (1803) — le judicial review

Dans l'atmosphère de lutte entre les Fédéralistes et les anti-fédéralistes, la CS affirma son pouvoir d'apprécier la constitutionnalité des lois fédérales dans l'affaire ***Marbury v. Madison*** (1803) — *judicial review*. C'est l'une des décisions les plus importantes de la Cour suprême des États-Unis.

Contexte et faits

En 1801, le président sortant John Adams (fédéraliste) nomme plusieurs juges de dernière minute, dont **William Marbury**. Cependant, le secrétaire d'État **James Madison**, sous les ordres du nouveau président Thomas Jefferson (républicain-démocrate anti-fédéraliste), refuse de délivrer la commission officielle à Marbury. Celui-ci porte plainte devant la Cour suprême pour obtenir son poste.

Monsieur Marbury avait fait l'objet de la procédure de désignation, son affectation ayant été signée par le Président, l'acte portant le sceau des États-Unis. La loi créant l'emploi lui conférait le droit de l'occuper pendant cinq ans. Mais dans cette période de grandes turbulences politiques, l'administration n'avait pas eu le temps de notifier à Marbury sa nomination.
Le nouveau Président, Jefferson, ordonna de ne pas notifier l'acte de nomination, pour le rendre sans effet. Marbury émit la prétention comme quoi il s'agissait d'un abus de pouvoir et saisit la Cour suprême pour qu'il soit fait injonction au nouveau secrétaire d'État, Madison, de lui signifier l'acte de nomination comme juge.



La décision de la Cour suprême

Le juge en chef **Marshall**, s'exprimant au nom d'une cour unanime, décida que même si Marbury avait légalement droit à la commission, la Cour suprême ne pouvait pas l'aider en délivrant un ordre de *mandamus*. La loi qui l'y autorisait — l'article 13 du Judiciary Act de 1789 — était en contradiction avec l'article III de la Constitution. La Cour prit la décision sans précédent d'annuler l'article 13.

⚖️ **Marbury v. Madison (1803) — Raisonnement en trois temps – Résumé**

1. La demande de Marbury et le pouvoir de la Cour suprême
Marbury demandait à la Cour suprême d'émettre un writ of mandamus, une injonction qui aurait forcé le secrétaire d'État James Madison à lui remettre sa commission. Or, la Cour devait d'abord vérifier si elle avait juridiction pour juger cette affaire.

2. Le Judiciary Act de 1789 et son conflit avec la Constitution
Le Judiciary Act de 1789 (section 13) donnait à la Cour suprême le pouvoir d'émettre un *writ of mandamus* en première instance. Cependant, l'article III de la Constitution définit strictement les cas où la Cour suprême peut exercer une juridiction originale : uniquement dans des cas impliquant des ambassadeurs, des ministres publics ou lorsque l'État est partie prenante. Dans l'affaire Marbury, aucun de ces critères ne s'appliquait.

3. L'inconstitutionnalité de la section 13
En donnant à la Cour suprême le pouvoir d'émettre un writ of mandamus en première instance dans une affaire comme celle-ci, le Judiciary Act étendait la juridiction originale de la Cour au-delà de ce que prévoit la Constitution. John Marshall et la Cour suprême ont donc conclu que cette disposition violait la Constitution et était inconstitutionnelle.

⚠️ **Conséquence majeure : naissance du contrôle judiciaire (judicial review)**
En déclarant une loi du Congrès inconstitutionnelle, la Cour suprême a établi le principe du **contrôle judiciaire (judicial review)**, qui lui permet d'invalider des lois qui ne respectent pas la Constitution. Cet arrêt a renforcé le rôle du pouvoir judiciaire dans le système fédéral américain.

L'arrêt pose que la Constitution est une **norme suprême et inaltérable par des moyens ordinaires**. Tous les juges judiciaires sont les gardiens de la constitutionnalité des normes (*théorie du contrôle diffus de constitutionnalité*). L'arrêt en vient à dire qu'une loi contraire à la Constitution n'est pas du droit.

💡 **Remarque**

Lien avec le fédéralisme : l'arrêt Marbury v. Madison renforce le fédéralisme en consolidant le pouvoir judiciaire fédéral. En affirmant le contrôle judiciaire, il établit la suprématie de la Constitution et renforce l'autorité du gouvernement fédéral sur les États. Cette décision donne à la Cour suprême le rôle d'arbitre ultime des conflits entre les pouvoirs et entre le niveau fédéral et étatique.

Par la suite, la Cour suprême se prononça également sur la **constitutionnalité des lois émanant des États fédérés**, imposa son autorité à l'égard des autres juridictions et jeta les bases de l'interprétation large des pouvoirs du Congrès.

📜 **Charles Evans Hughes (1908) — Le rôle de la Cour**

« Nous sommes soumis à une Constitution, mais la Constitution est ce que les juges disent qu'elle est. »

— Charles Evans Hughes, gouverneur de l'État de New York, discours devant la chambre de commerce d'Elmira (1908).

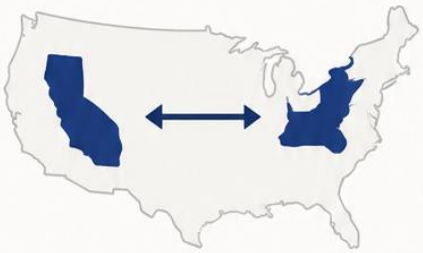
SECTION 2. LES TROIS FONCTIONS ESSENTIELLES DE LA COUR SUPRÊME

Aucune cour constitutionnelle dans aucun pays n'a joué et ne joue un rôle comparable à celui de la Cour suprême aux Etats-Unis (E. Zoller). Cette place exceptionnelle peut s'expliquer par l'importance de ses trois fonctions essentielles :

LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS

TROIS FONCTIONS ESSENTIELLES

1 RÉSOUDRE LES DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS



La Cour règle les différends impliquant les États de l'Union.

Elle statue aussi, indirectement, sur des litiges contre les États pour faire prévaloir la Constitution, les lois et les traités des États-Unis.

2 GARANTIR L'INTERPRÉTATION UNIFORME DU DROIT FÉDÉRAL



La Cour assure une interprétation et une application uniformes du droit fédéral : Constitution, lois fédérales et règlements édictés par les agences fédérales.

EXEMPLES D'AGENCES FÉDÉRALES

FCC
Médias et télécommunications

EPA
Protection de l'environnement
Massachusetts v. EPA (2007)

FTC
Commerce et concurrence

FDA
Médicaments et alimentation

Lien avec la Cour suprême : litige entre un État fédéré et une agence fédérale sur l'interprétation d'une loi nationale.

3 FAIRE RESPECTER LA CONSTITUTION



La fonction la plus importante : sans la Cour, la Constitution serait restée œuvre morte.

> *Nous sommes soumis à une Constitution, mais la Constitution est ce que les juges disent qu'elle est.*
>
> CHARLES EVANS HUGHES, 1908

La Cour a construit le statut juridique de la Constitution.

GARANTIE DE L'ÉTAT DE DROIT ET DE L'UNITÉ DE LA NATION

SECTION 3. COMPOSITION DE LA COUR SUPRÊME

§1. Statut et désignation des juges

📜 **Article III, Section 1 de la Constitution — Garanties d'indépendance**

Les juges de la Cour suprême, comme tous les juges fédéraux des cours inférieures établies par le Congrès, ont l'assurance :

- de conserver leurs charges tant qu'ils auront une *bonne conduite* (*during good Behaviour*) ;
- de ne pas voir leurs traitements diminuer en cours de fonction (*Compensation [...] shall not be diminished during their Continuance in Office*).

💡 **Remarque**

L'inamovibilité de fait dont ils bénéficient ne les distrait toutefois pas d'une éventuelle procédure de **destitution (impeachment)**, uniquement pour « trahison, corruption ou autres hauts crimes et délits » (*Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors*) conformément à l'Article II, Section 4.

⚖️ **Exemples historiques de procédures de destitution**

Samuel Chase (1804) : mis en accusation par les membres républicains de la Chambre des représentants, mais acquitté l'année suivante par le Sénat.
Abe Fortas (1969) : procédure déclenchée pour corruption et malversations financières ; n'alla pas à son terme par suite de démission anticipée de l'intéressé.
William O. Douglas (1953 et 1970) : fit l'objet de deux procédures de destitution qui n'aboutirent pas. Il se retira en 1975 au terme d'un mandat de trente-six ans et sept mois, le plus long mandat jamais exercé par un juge de la Cour.

La nomination des juges de la Cour suprême fait l'objet d'une **procédure en deux temps** : ils sont **désignés par le Président** et doivent être **confirmés par le Sénat** [Article II, Section 2 (2)]. Sur plus de deux siècles de pratique institutionnelle (1789-1996), le Sénat a rejeté vingt-huit fois les propositions présidentielles.

📌 **Exemple**
Sur les neuf juges qui composent la Cour suprême des États-Unis, cinq ont voté pour l'annulation de l'arrêt ***Roe v. Wade*** de 1973, le 24 juin 2022 : Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. Chacun a été nommé par un président des États-Unis, comme le prévoit la Constitution américaine. L'avortement n'est donc plus un droit protégé par la Constitution américaine.

§2. Organisation et fonctionnement

Les neuf juges de la Cour suprême constituent un seul et même collège, composé d'un **Président (Chief Justice)** et de huit **juges (Associate Justices)**. Par opposition à la tradition continentale de l'anonymat de la fonction judiciaire, les juges de la Cour suprême sont connus du grand public. Les arrêts (*opinions*) font apparaître la répartition des votes.

> 📖 **Définition — Per curiam**
> *Cette règle est écartée lorsque la décision de la Cour est rendue **per curiam**, c'est-à-dire lorsqu'aucun juge n'est désigné pour rédiger l'arrêt et que celui-ci est réputé avoir été écrit par la Cour tout entière.*

Cette solution exceptionnelle se recommande dans quatre situations :

- Montrer l'unanimité ou le consensus pour les décisions claires et peu controversées ;
- Décider rapidement ;
- Éviter la politisation ;
- Absence de question constitutionnelle complexe.

Ex. : *Buckley v. Valeo* (1976) — décision sur le financement des partis politiques, rendue per curiam.

> ⚖️ **Les grands présidents de la Cour suprême**
>
> **John Marshall (1755-1835)** — Président de la Cour de 1801 à 1835. Le plus grand président de la Cour, passé à l'histoire pour avoir été l'architecte judiciaire de l'unité nationale.
>
> **Earl Warren (1891-1974)** — Président de la Cour de 1953 à 1969. Instigateur d'une jurisprudence dynamique (*judicial activism*) qui a bouleversé non seulement les vieilles traditions des États du Sud, mais encore certains aspects de la société américaine en général, particulièrement dans le domaine de la protection des droits et libertés.

> 💡 **Remarque**
> En principe, le Président de la Cour est un simple primus inter pares. En pratique, la personnalité des titulaires de la charge donne à la fonction, selon les cas, un relief tout particulier.
> Les grands présidents laissent leurs noms attachés à la période correspondant à leur présidence.

> 📚 **Récapitulatif — Points clés à retenir**
> ✅ Montesquieu (1748) : première théorisation de la séparation de la puissance de juger des pouvoirs législatif et exécutif.
> ✅ L'article 3 de la Constitution (1787) fonde le pouvoir judiciaire fédéral et la compétence de la Cour suprême.

✅ Le débat Fédéralistes / Anti-fédéralistes aboutit à la Constitution (1789) + Bill of Rights (1791).
✅ Marbury v. Madison (1803) établit le judicial review : la Cour peut invalider toute loi contraire à la Constitution.
✅ Trois fonctions essentielles : arbitrage entre États, uniformité du droit fédéral, gardienne de la Constitution.
✅ Les juges sont nommés par le Président + confirmés par le Sénat, inamovibles, et protégés par l'Article III.
✅ La Cour siège en collège unique de 9 juges (1 Chief Justice + 8 Associate Justices). Décisions rendues au nom de la Cour entière.



Les juges de la Cour suprême, depuis juin 2022. Assis de gauche à droite : Sonia Sotomayor, Clarence Thomas, John G. Roberts, Jr. (juge en chef), Samuel Alito et Elena Kagan. Debout de gauche à droite : Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Ketanji Brown Jackson.